DOI: https://doi.org/10.30582/kdps.2023.36.2.77
UCI: G903:PD0-000036235

저작물의 공정이용 판단과 변형적 이용 기준의 역할

- 미국 Wofsy v. De Fontbrune 사건에 나타난 문제점을 중심으로 -

박 준 우*

논문

목 차

I. 서론

II. 사건의 개요
1. 사실관계
2. 제1심판결과 항소심판결
3. 상고이유

III. 법원의 판결과 상고이유에 대한 검토
1. 제1요소: 공정이용 규정 前文의 목적 예시와 제1요소의 '상업성'
2. 제2요소: 저작물성·실질적 유사성의 창작성과의 구별과 입법이유

IV. 제1요소와 다른 요소의 관계
1. '변형적 이용'의 의미와 기능
2. 제1요소와 제2요소의 관계와 변형적 이용
3. 제2요소의 독자적 존재 의의

* 서강대학교 법학전문대학원. 교수

※ 투고일자 : 2023년 04월 28일 / 심사일자 : 2023년 06월 15일 / 게재확정일자 : 2023년 06월 16일

4. 제3·4요소와의 관계, 그리고 표현의 자유
5. 논의의 정리

V. 결론: 제1요소와 변형적 이용 기준의 중요성

초 록

최근 문화산업 규모가 커지고 저작물을 소재로 이용하는 문화상품과 정보상품이 많아지면서, 미국 연방대법원은 Google v. Oracle과 Andy Warhol v. Goldsmith 등 주목할 만한 공정이용 판결들을 내렸다. 대법원도 최근 풍자포스터에 누드사진을 이용한 것이 공정이용이 아니라는 원심판결을 인용하였다. 법원으로서는 ① 새로운 유형의 사건에 대한 판결과 과거 판결에 적용된 공정이용법리의 일관성과 ② 판결들이 모두 저작권법의 목적에 부합한다는 것을 보여주는 것이 필요하다. 그러나 저작물의 종류 및 이용형태의 다양함과 공정이용 규정의 일반조항적 성격 등은 이를 힘들게 한다.

2022년 미국 제9연방항소법원은 '제르보스 카탈로그 사건'에서 피고의 사진저작물 이용행위가 공정이용이 아니라고 판결하였고, 연방대법원은 상고를 불허하였다. 이 사건 원고와 피고는 모두 화가 파블로 피카소 작품 사진집(카탈로그)을 발행하였는데, 원고가 저작권을 가진 피카소 작품 사진들을 피고가 일부 이용하였다. 원고와 피고의 카탈로그는 직접적으로 경쟁하는 관계에 있고, 피고가 원고저작물(사진)을 그대로 복제(dead-copy)한 점에서 공정이용으로 인정될 가능성은 별로 없었다. 그러나 이 사건의 제1심과 항소심 판결, 그리고 상고이유에는 공정이용을 판단할 때 흔히 보이는 문제점들이 잘 나타나 있다. 따라서 이 사건은 공정이용을 판단할 때 생길 수 있는 오류와 문제점을 설명하기에 매우 유용한 판결이다.

이 논문은 우선 '제르보스 카탈로그 사건'의 개요를 설명하고(II), 판결과 상고이유를 비교·분석하고(III), 공정이용 제1요소와 다른 요소의 관계를 검토한다. 그리고 ① 공정이용은 창작성(아이디어-표현 이분법), 실질적 유사성과 함께 저작자와 이용자(2차 창작자 또는 정보생산자) 사이에 창작 (또는 정보생산) 비용을 배분하기 위해서 양자의 표현의 자유를 비교형량하는 도구라는 점, ② 최근 'Warhol 사건'에서 연방대법원은 차용미술에 관하여 위 표현의 자유의 비교형량과 창작비용 배분의 문제를 해결할 수 있는 가능성을 보여준 점, ③ 제2요소는 독자적 존재 의의가 미약하므로 추후 공정이용 규정에서 삭제할지 검토할 필요가 있는 점, ④ 미국 연방대법원이 설시한 바와 같이 '공정이용의 각 요소들은 다른 요소들과 '따로'가 아닌 '함께' 고려한 후에, 이를 취합하여 저작권법의 목적에 부합하는 최종 결론을 내려야 함'을 저작권법에 명시할 것 등을 주장한다(IV).

주 제 어

창작성, 실질적 유사성, 공정이용, 변형적 이용, 표현의 자유, 창작비용, 2차 창작, 앤디워홀, 차용미술

I. 서론

미국 연방대법원은 2021년 저작물 공정이용에 관한 Google LL.C. v. Oracle Am., Inc. 판결을 내렸으며,[1] 2023년 5월 18일에 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith 판결을 내렸다.[2] 위 두 사건은 연방대법원 또는 원심판결 직후 평석이 나올 정도로 아직 저작권법 공정이용 판단사례가 상대적으로 적은 한국에서 관심을 받았다. 한국에도 그동안 공정이용이 문제된 사건들이 있었고,[3] 누드사진을 이용한 풍자포스터가 공정이용인지에 관한 대법원 판결도 있었다.[4]

2022년 미국 제9연방항소법원은 '제르보스 카탈로그 사건'에서 피고의 사진저작물 이용행위가 공정이용이 아니라고 판결하였고, 연방대법원은 2023년 4월 3일 상고를 불허하였다.[5] 이 사건 원고와 피고는 모두 화가 파블로

1) 141 S.Ct. 1183 (2021). 이 사건에 대한 평석은, 김창화, "Google v. Oracle 판결에서의 공정이용에 관한 연구", 『산업재산권』, 제68호, 한국지식재산학회(2021); 정진근, "Google v. Oracle 판결에서의 저작물 공정이용(fair use) 법리: 관련 산업에의 영향", 『산업재산권』, 제68호, 한국지식재산학회(2021). 연방대법원 판결 이전 평석으로는, 육소영, "오라클과 구글의 저작권 분쟁과 산업계의 영향", 『IT와법연구』, 제22집, 경북대학교 IT와법연구소(2021); 김도경, "응용프로그램인터페이스(API)에 관한 Oracle v. Google 사건판결의 영향과 전망: 공정이용 인정여부를 중심으로", 『경영법률』, 제30권 제3호, 한국경영법률학회(2020).

2) 143 S.Ct. 1258 (2023)(이하 'Warhol 사건'). 이 사건 항소심(원심)은 공정이용이 아니라고 판단하였는데, 상고인(Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.)은 공정이용 4요소 중 제1요소(이용의 목적과 성격) 판단에 대해서만 다투었기 때문에, 연방대법원도 제1요소만 판단하였고, 제1요소는 공정이용이 아니라는 원심판결을 인용하였다. 위 사건, 1266쪽. 이 사건의 항소심판결에 대한 평석은, 류시원, "공정이용 판단의 고려요소로서 '변형적 이용'의 한계: 미국 연방법원의 Andy Warhol Foundation v. Goldsmith 사건을 중심으로", 『계간저작권』, 제140호, 한국저작권위원회(2022).

3) 저작권법에 공정이용 규정이 신설된 이후 2023년 3월 15일까지 공정이용이 쟁점이 된 판결·결정들의 요약과 평가에 관해서는, 이일호, "우리 저작권법상 공정이용의 운영 현황과 과제: 판례를 중심으로", 『계간저작권』, 제141호, 한국저작권위원회(2023).

4) 대법원 2020. 6. 25. 선고 2017도5797 판결(열정페이포스터). 다만, 이 사건에서 피고인포스터가 비판한 대상은 고소인이나 고소인이 촬영한 사진이 아닌 사진의 피사체였던 패션디자이너였다. 또한 대법원은 공정이용이 아니라고 한 원심판결을 단순히 인용하였고 별다른 판결이유는 제시하지 않았다. 이 판결에 대한 평석으로는, 최상필, "패러디의 허용 범위와 표현의 자유: 대법원 2020. 6. 25. 선고 2017도5797 판결을 참고하여", 『산업재산권』, 제72호, 한국지식재산학회(2022).

5) De Fontbrune v. Wofsy, 39 F.4th 1214 (9th Cir. 2022), *cert. denied*, 143 S.Ct. 1084 (Apr. 3, 2023) (No. 22-531)(이하 '제르보스 카탈로그 사건'). 이 사건의 개요를 소개한 글은

피카소 작품 사진을 모은 카탈로그를 발행하였는데, 원고가 저작권을 가진 피카소 작품 사진들을 피고가 일부 이용하였다.[6] 원고와 피고의 카탈로그는 직접적으로 경쟁하는 관계에 있고, 피고가 원고저작물(사진)을 그대로 복제(dead-copy)한 점에서 연방대법원의 상고불허는 예상되었다. 그러나 이 사건의 제1심과 항소심 판결, 그리고 상고이유에는 공정이용을 판단할 때 흔히 보이는 문제점들이 잘 나타나 있다. 따라서 이 사건은 공정이용 판단에 대한 오류와 문제점을 설명하기에 매우 유용한 판결이다. 미국을 포함한 이른바 법률 선진국 법리는 힘닿는 한 검증을 거쳐 한국 판결, 법률, 학술문헌에 반영하여야, 선진국 법률가들이 오해한 법리 위에 한국 법리가 축적되는 것을 최대한 줄일 수 있다.

이 논문은 우선 '제르보스 카탈로그 사건'의 개요를 설명하고(II), 판결과 상고이유를 비교·분석하고(III), 공정이용 제1요소와 다른 요소의 관계를 검토한다. 그리고 ① 공정이용은 창작성(아이디어-표현 이분법), 실질적 유사성과 함께 저작자와 이용자(2차 창작자 또는 정보생산자) 사이에 창작(또는 정보생산) 비용을 배분하기 위해서 양자의 표현의 자유를 비교형량하는 도구라는 점, ② 최근 'Warhol 사건'에서 연방대법원은 차용미술에 관하여 위 표현의 자유의 비교형량과 창작비용 배분의 문제를 해결할 수 있는 가능성을 보여준 점, ③ 제2요소는 독자적 존재 의의가 미약하므로 추후 공정이용 규정에서 삭제할지 검토할 필요가 있는 점, ④ 미국 연방대법원이 설시한 바와 같이 '공정이용의 각 요소들은 다른 요소들과 '따로'가 아닌 '함께' 고려하여 판단한 후에, 이를 취합하여 저작권법의 목적에 부합하는 최종 결론을 내려야 함'을 저작권법에 명시할 것 등을 주장한다(IV).

다음과 같다: 김혜성, "법원, 카탈로그에 수록된 피카소 작품 사진을 이용한 것은 공정이용에 해당한다", 『저작권동향』, 제19호, 한국저작권위원회(2019); 최푸름, "제9회순회항소법원, 외국 법원의 저작권 침해 판결 인정과 보상금 산정을 위해 캘리포니아 인정법 적용", 『저작권동향 2022』, 한국저작권위원회(2022), 450쪽.

6) 독일 연방대법원에도 박물관이 출판한 책에 수록된 저작권 보호기간이 지난 회화·조각 등의 사진을 촬영하여 인터넷에 올린 사건이 있었는데, 독일 저작권법은 사진저작물이 아닌 사진도 저작인접물로 보호한다. 계승균, "책에 수록된 사진 등을 촬영하여 인터넷에 올린 행위에 관한 판례연구(BGHZ 1 ZR 104/17)", 『계간저작권』, 제132호, 한국저작권위원회(2020).

II. 사건의 개요

1. 사실관계

사진작가 Christian Zervos(이하 '제르보스')는 1926년 파리에 출판사 'Cahier d'Art'를 설립하고 같은 이름의 미술잡지를 발행하였다. 그리고 1932년부터 화가 파블로 피카소의 'catalogue raisonné'(이하 '원고 카탈로그')[7]를 발행하였는데, 원고 카탈로그에는 피카소 작품을 찍은 사진 16,000점이 실렸다. 원고 카탈로그 마지막 권은 1978년에 발행되었고 이후 절판되었다가 2010년에 재발행되었다.[8] 1979년 Sicre de Fontbrune은 원고 카탈로그에 대한 지식재산권을 포함한 Cahier d'Art의 영업자산(business capital)에 대한 권리를 양수하였다. Alan Wofsy Fine Arts LLC는 1991년에 파블로 피카소 재단의 동의를 받고 피카소 작품을 연대 순서로 실은 『The Picasso Project』(이하 '피고 카탈로그')라는 책을 발간하였는데, 원고 카탈로그의 사진 1,492점(이하 '원고사진')을 복제하여 실었다.

1996년에 Sicre de Fontbrune은 파리의 책 박람회에서 '피고 카탈로그'가 판매되는 것(offered for sale)을 알고 저작권 침해 소송을 제기하였다. 이에 대하여 1998년 프랑스 제1심법원(the Tribunal de Grande Instance de Paris)은 '원고 카탈로그의 사진은 기록물의 성격(documentary in nature)을 가지므로' 저작권 보호 대상이 아니라고 하였다. 그러나 2001년 프랑스 항소법원(Cour d'Appel)은 원고사진에는 "조명, 렌즈, 필터, 구도, 각도 등의 의도적 선택을 통한 창작적 특징이 있다."며[9] 저작권 침해를 인정하였

7) 'catalogue raisonné'란 '특정 화가의 모든 작품을 담은 카탈로그'를 의미한다. '제르보스 카탈로그 사건'(주5), 1219쪽 주2. '카탈로그 레조네'는 프랑스어로 '검토한 작품을 모은 도록'이라는 뜻인데, "작가가 평생 제작한 모든 작품과 함께 소장, 전시 이력 등의 기록을 수록한 자료다." 통상 작가당 하나의 카탈로그 레조네를 발행하며, 프로비넌스와 함께 작품의 진위를 판명할 때 사용되는 주요 자료이다. 전하영, "[아트테크가 뭐길래] 아트테크 입문자가 알아두면 좋을 기본 용어", 동아일보, 2021. 8. 2.

8) George Stolz, "The $20,000 Picasso Catalogue the Art World Was Waiting For", ARTnews, June 3, 2014.

다. 그리고 앞으로 피고가 원고 저작권을 침해할 때마다 1만 프랑의 위약금을 지급(astreinte)할 것을 명하였다.[10]

2011년 '피고 카탈로그'가 프랑스 책방에서 판매되었는데, 이를 이유로 2011년 6월 22일 Sicre de Fontbrune은 Wofsy에 대하여 위약금 지급 소송을 제기하였다. 피고는 이 소송에 출석하지 않았고(또는 못했고) 프랑스 제1심법원은 2012년 1월 10일 2백만 유로를 원고에게 지급하라는 판결을 내렸다. 원고는 2013년 위 프랑스 판결을 미국에서 강제하기 위한 소송을 제기하였으나, 캘리포니아주 연방제1심법원은 2019년 9월 12일 '피고 카탈로그에 원고 카탈로그 사진을 복제한 것은 미국 연방저작권법의 공정이용에 해당하므로, 프랑스 판결을 강제하는 것은 미국의 공공정책에 반한다.'는 이유로 피고 승소의 약식판결을 내렸다.[11] 그러나 제9연방항소법원은 2022년 7월 13일 피고이용이 공정이용에 해당하지 않는다는 이유로 원고승소판결을 내렸다. 2022년 12월 5일 피고는 상고이유서(petition for writ of certiorari)를 제출하였으나 연방대법원은 2023년 4월 3일 상고를 불허하였다.

2. 제1심판결과 항소심판결

제1심판결과 항소심판결 중 공정이용 판단 부분은 다음과 같다.

(1) 제1요소: 피고 이용의 목적과 성격

제1심법원은 피고 카탈로그는 상업적 성격을 가졌지만, 다음 사실을 이유로 제1요소는 공정이용 쪽으로 강하게 기운다고 판단하였다: ① 피고 카탈로그는 도서관, 교육·연구기관, 미술품수집가, 경매전문업체 등을 위해 만든(intended for) 참고서적이므로,[12] 연방저작권법 제107조 전문(preamble)

9) "added creative features through "deliberate choice[s] of lighting, the lens, filters, [and] framing or angle of view."" '제르보스 카탈로그 사건'(주5), 1219쪽.

10) 피고는 프랑스 민사최고법원(Cour de Cassation)에 상고하였으나, 피고가 항소법원이 결정한 손해배상액과 비용을 지급하지 않자 각하하였다. 위 사건, 같은 쪽.

11) De Fontbrune v. Wofsy, 409 F.Supp.3d 823 (N.D.Cal. 2019)(이하 ''제르보스 카탈로그 사건' 1심').

의 '공정이용 목적 예시'[13]에 해당한다; ② 피고 카탈로그에는 해당 사진의 제목, 관련 참고문헌, 프로비넌스(provenance. 소장이력),[14] 현재 소유자, 구매정보 등의 정보가 있었는데, 원고사진에는 위 정보가 거의 없었다. 원고는 위 사실에 이견이 없었지만, '피고가 상업적 목적으로 복제하였음'을 이유로 제1요소는 공정이용이 아닌 쪽으로 기운다고 주장하였다. 이에 대하여 제1심법원은 '피고 카탈로그의 성격이 상업적이라는 이유만으로 공정이용이 아니라고 추정한다면, 제107조 전문에 열거된 공정이용 예시 대부분은 공정이용이 아니라는 추정을 받을 것이다. 왜냐하면, 위 예시들은 대부분 영리목적이기 때문'이라며,[15] 원고 주장을 배척하였다. 참고로 제1심법원 판결문에는 '변형적 또는 생산적'이라는 표현이 전혀 나오지 않는다.

제9연방항소법원은 다음을 이유로 제1요소는 공정이용이 아닌 쪽으로 기운다고 판단하였다. 항소법원은 우선 다음 기준을 제시하였다: ① '피고 이용의 목적과 성격'을 고려하는 가장 중요한 목적(central purpose)은 '피고 카탈로그가 변형적인지'를 판단하는 것이다. '변형적'이란 '추가적인 목적이나 다른 성격을 가진 새로운 것을 추가하여, 새로운 표현, 의미 또는 메시지로 원고사진을 변경하는 것'을 의미한다;[16] ② 또한 똑같이 복제(exact copy)해도 변형적일 수 있다. 예를 들면 인터넷 검색결과인 피고의 썸네일 이미지는 원

12) 실제로 피고 카탈로그는 원고 카탈로그보다 상대적으로 낮은 가격 때문에 위 기관들에 대해 경쟁력(attractive)이 있었다.

13) "비평, 논평, 시사보도, 교육(학습용으로 다수 복제하는 경우를 포함), 학문, 또는 연구 등의 목적". 미국 연방저작권법 제107조. "… for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, …." 번역은 한국저작권위원회 홈페이지 미국 연방저작권법 번역본을 참고하였다.

14) '프로비넌스'란 미술품을 소장한 이력 또는 기록이며, "미술품 특성상 유명한 컬렉터나 기관이 소장했던 작품일수록 그 가치가 높아진다." 전하영(주7), 앞의 자료. 예술품의 진위를 결정할 때 객관적인 근거 자료로 활용된다. 최근에는 프로비넌스 기록에 블록체인 기술을 활용하여 그 신뢰도를 높이고 있다. 양경록, "알면 알수록 빠져드는 미술세계 엿보기", 카이스트신문, 2021. 10. 5.

15) Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 584 (1994)(이하 'Campbell 사건') 인용.

16) '제르보스 카탈로그 사건'(주5), 1224쪽. "The "central purpose" of considering the "purpose and character" of the work is to determine whether the new work is "transformative"—that is, whether it "adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message."" Harper & Row Publ'ers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539, 562 (1985)(이하 'Harper 사건') 인용.

고 이미지와는 **전혀 다른 기능**(정보접근향상)을 가졌으며, 낮은 해상도 때문에 원고 이미지와 같이 삽화 또는 심미적 목적으로 사용할 수 없으므로 '변형적'이다.[17] 그리고 항소법원은 피고 카탈로그가 '도서관, 교육·연구기관, 미술품 수집가, 경매전문업체 등을 위한 것(intended for)'이라도, '최종이용자의 활용'은 제1요소와는 거의 관계없음을 이유로 피고이용은 변형적이지 않다고 판단하였다.[18]

이에 대하여 피고는 '원고사진이 가진 창작적 품질과는 관계없이 기록의 목적으로만 이용하였을 뿐'이라고 항변하였다. 그러나 항소법원은 다음을 이유로 피고항변을 배척하였다: ① 단순히 목적이 다르다는 점은 변형적 이용을 인정하기에 충분하지 않다; ② 게다가 원고사진과 피고 카탈로그는 모두 '피카소 작품을 나타낸다는 목적'을 공유하므로, 피고 카탈로그가 원고사진과 전혀 다른 기능을 수행한다고 할 수 없다; ③ 또한 피고가 연구를 쉽게 하도록 원고사진을 배열하고 설명(informative caption)을 추가한 것이 곧 원고사진을 변형한 것이라고 할 수도 없다.

(2) 제2요소: 원고저작물의 성질

제1심법원은 다음을 고려하면 제2요소는 공정이용이 아닌 쪽으로 살짝 기운다고 판단하였다: ① 2001년 프랑스 항소심판결과 같이 원고사진은 '조명, 렌즈, 필터, 구도, 각도 등을 의도적으로 선택'한 것에서 창작성을 인정할 수 있다; ② 반면 원고 카탈로그와 같은 카탈로그 레조네의 목적은 해당 미술가의 작품을 충실하게 재현(reproduce)하는 것이므로 원고사진의 성격은 기록물(documentary)이며, 원고도 이를 다투지 않았다.[19]

제9연방항소법원은 제2요소는 원고사진의 창작성 정도 때문에 공정이용 쪽으로 심하게 기운다고 할 수 없다고 판단하였다.[20] 항소법원은 우선 제2요소

17) '제르보스 카탈로그 사건'(주5), 1224-1225쪽. Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811, 818-819 (9th Cir. 2003)(이하 'Kelly 사건') 인용.

18) "The end-user's utilization of the product is largely irrelevant." Zomba Enters., Inc. v. Panorama Recs., Inc., 491 F.3d 574, 582 (6th Cir. 2007) 인용.

19) '제르보스 카탈로그 사건' 1심(주11), 842쪽.

20) '제르보스 카탈로그 사건'(주5), 1225-1226쪽. "The photographs' creative qualities prevent this factor from weighing heavily, if at all, in favor of fair use." 참고로 항소법원은

는 '(원고)저작물의 ① 창작성 정도와 ② 미공표(unpublished) 여부[21]'라는 두 측면을 고려하는 것이라고 하였다.[22] 그런데 이 사건에서 원고사진은 원고 카탈로그에 공표(published)되었으므로, 제2요소의 결정의 초점은 창작성 정도에 있다고 하였다. 그리고 원고사진의 목적이 '기록물'이라는 피고 주장에 대해서 '기록물이라는 사진의 목적이 그 사진의 창작적 성격을 부인하는 것은 아니'라고 하였다. 또한 피고는 "① 카탈로그 레조네 사진은 일반적으로 예술적 목적이 없으며, ② 원고 카탈로그 사진들은 예술작품이 아니"라는 저명한 미술사학자의 의견을 제시하였다. 그러나 이에 대하여 항소법원은 프랑스 항소법원이 원고사진의 창작성을 인정하였다고 답하였다.

(3) 제3요소: 원고저작물 중 이용된 양과 질

제1심법원은 우선 제3요소는 ① 이용된 부분의 양과 실질이 복제 목적에 비추어 합리적인지를 판단하는 것이며,[23] ② 양적 요소와 질적 요소를 모두 가지므로, 피고가 원고 저작물 중 양적으로 상당한 부분 또는 질적으로 핵심적인 부분을 베꼈다면 공정이용이 아니라고[24] 하였다. 그리고 다음을 이유로 제3요소는 공정이용 쪽으로 기운다고 하였다: ① 피고가 원고사진 1만 6천 점 중 1,492점을 복제하였는데, 이는 전체 원고사진의 10%도 안 되는 점, ② 피고 카탈로그는 원고 카탈로그에 창작성을 부여한 제르보스의 '선택·배열이나 의도된 표현'을 복제하지 않은 점; ③ 피고가 이용한 원고사진들이 원고 카탈

판결문 1227쪽에서 "(원고)저작물 성격이 공정이용 쪽으로 기운다고 하더라도(even if the nature of the copyrighted works were to favor fair use)"라고 하였다.

21) '미공표저작물은 공표된 저작물보다 공정이용 인정 범위가 좁다'는 'Harper 사건'(주16), 564쪽 인용.

22) Monge v. Maya Mags., Inc., 688 F.3d 1164, 1177 (9th Cir. 2012) 인용.

23) '제르보스 카탈로그 사건' 1심(주11), 842쪽. "asks whether the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole, are reasonable in relation to the purpose of copying." Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods., 353 F.3d 792, 803 (9th Cir. 2003) 인용.

24) '제르보스 카탈로그 사건' 1심(주11), 842쪽. "This factor has both a quantitative and a qualitative component, so that courts have found that use was not fair where the quoted material formed a substantial percentage of the copyrighted work … or where the quoted material was essentially the heart of the copyrighted work." New Era Publ'ns Int'l, ApS v. Carol Publ'g. Grp., 904 F.2d 152, 158 (2d Cir. 1990) 인용.

로그 중 핵심에 해당한다는 증거가 없는 점.[25]

제9연방항소법원은 이 사건과 같이 전부를 복제하였어도 변형적 복제라면 공정이용을 인정할 수 있지만, 이 사건에서 피고가 원고사진 전부를 복제한 것은 변형적 이용이 아니므로 제3요소는 공정이용이 아닌 쪽으로 기운다고 하였다.[26]

(4) 제4요소: 저작물의 가치 또는 잠재적 시장에 대한 영향

제1심법원과 항소법원 모두 "제4요소가 공정이용의 가장 중요한 요소임에 의문의 여지가 없다."는 'Harper 사건' 판결을 인용하였다.[27]

제1심법원은 다음을 이유로 원고 카탈로그와 피고 카탈로그는 경쟁 관계가 아니므로 제4요소는 공정이용 쪽으로 심하게 기운다고 판단하였다. 첫째, 피고 카탈로그는 한 권에 약 150달러, 전집(모두 28권)에 2,780, 3,400 또는 3,780달러(소매가격)인 반면, 원고 카탈로그 초판은 중고시장에서만 판매되며, 2013년 재판(reprint, 전집으로만 판매)은 2만 달러에 판매되고 있다. 둘째, 피고 카탈로그는 도서관, 교육·연구 기관, 미술품수집가, 경매전문업체 등을 위한(intended for) 것이지만, 원고 카탈로그는 그 역사적 성격과 높은 가격 때문에 틈새시장(niche market)을 가졌고, 원고도 이 점에 대해 다투지 못하고 있다. 셋째, 원고는 피고가 원고사진을 피고 카탈로그에 이용함으로써 원고 카탈로그 시장에 미친 영향을 전혀 증명하지 못하였다.[28]

제9항소법원은 다음을 이유로 제4요소는 공정이용이 아닌 쪽으로 기운다고

---

25) "… sequences and the specific representations which, coming from the personal choices of Mr. ZERVOS …." '제르보스 카탈로그 사건' 1심(주11), 842-843쪽. 프랑스 항소심판결 인용.

26) '제르보스 카탈로그 사건'(주5), 1226쪽. 'Kelly 사건'(주17), 821쪽 인용.

27) "is undoubtedly the single most important element of fair use." 'Harper 사건'(주16) 인용.

28) 이는 공정이용 제4요소에 대한 증명책임이 원고에게 있다는 의미까지는 아니며, 다음의 증거에 대한 반대 증거를 원고가 제출하지 못하였다는 의미 정도로 보인다. 피고 카탈로그는 1995년에 발행되었는데, 원고 카탈로그는 1994년과 1995년에 소더비 경매에서 각각 35,000달러와 38,900달러에 낙찰되었다. 이후 2007년부터 2011년 사이에 3개 이상의 경매에서 10만 달러 이상에, 2012년의 한 경매에서는 74,200달러에 낙찰되는 등 가격이 가파르게 올랐다. 그러나 이후 가격이 계속 내려 2015년 한 경매에서 8,750달러에 낙찰되었는데, 이는 원고가 2013년에 원고 카탈로그 재판(reprint)을 발행하였기 때문으로 보인다.

판단하였다. 첫째, 제4요소를 판단할 때 "피고 카탈로그의 영향 자체뿐만 아니라 피고 행위와 같은 종류의 행위가 제약 없이 광범위하게 이루어졌을 때 원고시장에 미칠 잠재적인 부정적 효과도 고려"한다고 하였다.[29] 그런데 피고가 제시한 원고 카탈로그 경매 가격 상승 증거는 '피고 카탈로그가 원고 카탈로그 시장을 위축(depress)시키지 않았다는 정황증거'이지만, '원고사진의 라이선스 시장에 대한 영향'을 증명하지는 못한다. 둘째, 피고 카탈로그와 같이 피고작품이 상업적이고 非변형적이면(both commercial and non-transformative), 원고시장에 대한 부정적 영향(market harm)을 미치는 것으로 추정되는데,[30] 이에 대한 반증이 없다.

3. 상고이유

상고이유의 요지는 제9연방항소법원의 공정이용 제1, 2, 3요소 적용에 오류가 있었으며, 이는 다른 5개 연방항소법원의 입장과도 다른데, 이번 기회에 연방대법원이 공정이용의 해석에 대한 연방항소법원들 사이의 차이를 없애고 표현의 자유를 확실하게 보호해야 한다는 것이다. 다음에서 소개한다.[31]

(1) 제1요소

피고는 상고이유서에서, '제9연방항소법원은 제1요소와 관련하여, 단순히 피고 카탈로그가 판매에 제공되었다는 것만을 이유로 도서관, 학교, 박물관, 수집가, 경매전문업체 등을 위해 만든 학문적인 참고서적(피고 카탈로그)의 성격을 "상업적"이라고 하였는데, 이는 제2연방항소법원의 입장과 다르다.'고

29) "whether unrestricted and widespread conduct of the sort engaged in by the defendant would result in a substantially adverse impact on the potential market for the original." 'Campbell 사건'(주15) 인용.

30) Leadsinger, Inc. v. BMG Music Pub., 512 F.3d 522, 531 (9th Cir. 2008)을 인용한 Disney Enters., Inc. v. VidAngel, Inc., 869 F.3d 848, 861 (9th Cir. 2017) 인용.

31) 이 밖에 피고는 공정이용에 관하여 연방항소법원들 사이에 해석의 차이가 있다면, 자신의 표현이 공정이용의 보호를 받을 수 있는지 알 수 없어 스스로 표현을 자제하는 '표현에 대한 억제효과'가 생기므로, 연방대법원은 연방항소법원들 사이의 공정이용에 대한 해석의 충돌을 해결하여야 한다고 주장하였다. Petition for Writ of Certiorari, Wofsy v. De Fontbrune, 23 (Filed on 2022. 12. 5)(22-531)(이하 '상고이유서').

주장하였다.[32] 피고가 근거로 제시한 제2연방항소법원 판결은 Wright v. Warner Books, Inc.인데,[33] 피고작가는 유명 소설가에 대한 전기문을 작성하면서 그 소설가의 편지, 일기, 책, 수필 등의 일부를 발췌하여 직접 또는 간접적으로 인용하였다.[34] 피고는 상고이유서에서 연방대법원은 다음과 같은 두 항소법원 사이 해석의 차이를 해결해야 한다고 주장하였다:[35] ① '제르보스 카탈로그 사건'에서 제9연방항소법원은 피고 카탈로그가 판매에 제공되었다는 점만으로 피고이용의 상업성을 판단하고, 대부분의 학술적인 책들이 판매에 제공된다는 현실과 기타 관련된 모든 상황을 무시하였다; ② 반면, 제2연방항소법원은 'Wright 사건'에서 피고전기문의 저자와 출판사가 이윤을 기대함에도 불구하고 피고전기문의 학술·연구물이라는 성격 때문에 공정이용 쪽으로 기운다고 판단하였는데, 이는 'Campbell 사건'의 연방대법원 해석과 일관된다.

(2) 제2요소

피고는 상고이유서에서, 제9연방항소법원은 원고사진에 저작물로서의 창작성이 있으면 언제나 제2요소와 관련하여서도 '창작적'이라고 결론 내렸는데,[36] 이러한 순환논법(circular analysis)은 '저작물성의 창작성'만으로는 '공정이용 제2요소 관련 창작성'을 증명하기에 충분하지 않다는 제5, 11연방항소법원의 해석과 충돌한다고 주장하였다.[37]

피고가 근거로 제시한 제5연방항소법원 판결은 Compaq Computer Corp. v. Ergonome Inc.이다. 이 사건에서 제5연방항소법원은 '공정이용은 저작권 침해 판단이 잠정적으로 내려진 이후에 판단하므로, 공정이용 판단은 원고작품의 창작성을 전제로 한다. 그러므로 공정이용 제2요소는 원고작품에 창작성이 있다는 것 이상을 뜻한다.'고 하였다.[38] 그리고 제11연방항소법원

32) 위 상고이유서, 12쪽.
33) 953 F.2d 731 (2d Cir. 1991)(이하 'Wright 사건').
34) 참고로 이 사건의 원고는 소설가의 미망인이었다.
35) '상고이유서'(주31), 13-14쪽.
36) "a copyrighted work is "creative" under [the second] factor whenever the work is creative enough to be copyrightable." 위 상고이유서, 15쪽.
37) 위 상고이유서, 15, 18쪽.

은 Cambridge Univ. Press v. Patton에서 이를 인용하였다.[39] 피고는 원고 사진은 피카소 작품의 외관이라는 사실을 전달하고 있는데, 이처럼 사진에 사실적 요소가 있으면, 제11연방항소법원은 공정이용 제2요소를 판단하기 위해 사진의 창작적 요소와 사실적 요소를 서로 비교한다고 주장하였다. Katz v. Google Inc.에서 동법원은 '사진의 창작적 가치가 명백히 사실적인 요소를 압도하는지'를 평가하였다는 것이다.[40]

피고는 상고이유서에서 제2요소를 공정이용 쪽으로 판단해야 한다는 두 번째 근거로서 '피고사진의 사실성이 크기 때문에 창작성이 없거나 매우 약하다는 점'을 주장하였다. 제2연방항소법원은 "저작물을 복제한 것에[41] 창작성을 인정받으려면, 단순히 다른 매체로 전환함에 따른 사소한 변형 정도로는 부족하고, 상당한 정도의 변형이 인정되어야 한다."고 판단하였다.[42] 그런데 원고 카탈로그 사진들이 미국 연방저작권법의 창작성 요건을 충족하더라도, "주로 피카소 그림의 외관에 관한 사실적 정보를 전달하기 때문에 약한 보호를 받을 수밖에 없다."는 것이다.[43]

(3) 제3요소

제9연방항소법원은 피고가 원고사진을 이용하면서 일부분이 아닌 전부(entirety)를 이용하였음을 이유로 제3요소를 공정이용이 아닌 쪽으로 판단하였다. 피고는 상고이유서에서 제9연방항소법원의 위와 같은 해석은 제1, 2, 7, 11연방항소법원의 입장과 다르므로 연방대법원이 이를 바로잡아야 한다(rectify)고 주장하였다.[44]

---

38) "because fair use excuses otherwise actionable infringement. Thus, a work will always be found "original" for copyrightability purposes before the fair use analysis is applied. The second statutory fair use factor, then, refers to the "nature" of the work beyond this initial inquiry." 387 F.3d 403, 410 (5th Cir. 2004).
39) 769 F.3d 1232, 1268 n25 (11th Cir. 2014).
40) 802 F.3d 1178, 1183 (11th Cir. 2015)(이하 'Katz 사건').
41) 저자 註: '제르보스 카탈로그 사건'에서는 피카소 작품을 촬영한 원고사진을 의미한다.
42) L. Batlin & Son, Inc. v. Snyder, 536 F.2d 486, 491 (2d Cir. 1976).
43) '상고이유서'(주31), 18쪽. "Even if the Zervos Catalogue photographs would be copyrightable in the U.S., any such copyright would be "thin" because they primarily convey factual information about the appearance of Picasso's paintings."
44) 위 상고이유서, 22쪽.

피고가 상고이유서에서 제시한 판결 중 '제르보스 카탈로그 사건'과 사실관계가 가장 유사한 Ty, Inc. v. Publications Int'l Ltd.에서 피고는 원고사진을 이용하여 Beanie Babies Collector's Guide를 발행하였다. 위 가이드는 Beanie Baby 사진 외에도 출시일, 생산종료일, 추정 가격, 기타 수집가 관련 정보 등을 담았다. 제7연방항소법원은 "Beanie Baby 사진의 일부분(part)을 원하는 자는 없을 것이므로 Beanie Baby를 묘사하면서 사진 일부분을 복제(partial copying)하는 경우는 사실상 없을 것이고, 따라서 제3요소는 'Ty 사건'에 적용할 수 없다."고 하였다.[45] 위 가이드와 마찬가지로 피고 카탈로그도 피카소 그림 관련 문헌정보, 출처, 창작 장소, 현재 소유자, 판매 관련 정보들을 싣고 있고 그 목적도 피카소 작품을 기록으로 남기는 것인데, 피카소 작품 이미지 전부가 아닌 [일부분만을 이용하여] 기록물을 남기는 것은 불가능하다고 주장하였다. 결국 제7연방항소법원의 판결문을 빌리면, '피카소 작품의 일부분만 찍은 사진을 원하는 자는 아무도 없을 것'이라는 주장이다.

또한 피고는 제11연방항소법원 외의 다른 연방항소법원들도 '피고이용이 원고저작물 전부 복제를 필요로 하는 경우에는, 제3요소를 중립적으로, 즉 공정이용 쪽도 그 반대쪽도 아닌 것으로 해석했다.'고 주장하였다.[46] 그리고 사진 전부를 이용하지 않으면 의미가 없다는(useless) 판결의 다른 예시로서, ① 임대사업자의 관행을 비판하는 글을 실은 블로그에 그 임대사업자의 사진 전부를 게재한 경우(제11연방항소법원),[47] ② 특정 사진에 대한 기사에 그 사진 전부를 게재한 경우(제1연방항소법원),[48] ③ 특정 록밴드 역사에 관한 책에서 그 록밴드 콘서트 홍보 포스터 사진 전부를 게재한 경우(제2연방항소법원)[49] 등을 제시하였다.

45) 292 F.3d 512, 522 (7th Cir. 2002). 제르보스 카탈로그 사건의 피고는 이를 '제7연방항소법원이 제3요소를 공정이용 쪽으로도 또는 공정이용 반대쪽으로도 기울지 않은 중립적(neutral)이라고 판단했다.'고 주장하였다. '상고이유서'(주31), 21쪽.

46) '상고이유서'(주31), 21쪽.

47) 'Katz 사건'(주40), 1183-1184쪽.

48) Nunez v. Caribbean Int'l News Corp., 235 F.3d 18, 24 (1st Cir. 2000).

49) Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605, 613 (2d Cir. 2006)(이하 'Bill Graham Archives 사건').

III. 법원의 판결과 상고이유에 대한 검토

위에서 소개한 '제르보스 카탈로그 사건' 제1심판결, 항소심판결, 상고이유의 공정이용 판단을 고려요소별로 비교하면, 다음의 '표 1'과 같다.

표 1. 공정이용 요소별 제1심법원, 항소법원, 상고이유 요지 비교

	제1심	항소심	상고이유
제1요소	**공정이용-강함** - 피고 카탈로그: 도서관·교육·연구기관·수집가·경매업체 등을 위한 참고서적임 - 상업성은 중요치 않음 ※ '변형성'에 관한 언급 없음	**非공정이용** - 피고 카탈로그: 변형적이지 않음 - '최종이용자의 활용'은 관계없음	항소심은 피고 카탈로그의 상업성에 지나치게 큰 비중을 두고 판단
제2요소	**非공정이용-약함** - 원고사진 창작성 인정 - 원고사진은 기록물	**非공정이용-약함** - 원고사진의 창작성 정도와 공개 여부 고려 - 프랑스 항소법원의 결정	저작물의 창작성 판단과 공정이용 제2요소 판단은 다름
제3요소	**공정이용** - 양적 비중 약함 - 질적 비중에 대한 증거 없음 ※ 서적 對 서적 비교	**非공정이용** - 사진 전부 복제 - 非변형적 ※ 사진 對 사진 비교	사진 전부 복제가 불가피한 상황임
제4요소	**공정이용-강함** - 가격과 판매시장이 다름 - 원고시장 영향 증거 없음	**非공정이용** - 피고이용의 상업성·非변형성은 원고시장에 대한 부정적 영향 추정 - 반증 없음	상고이유 없음 ※ 다만, 표현의 자유에 대한 억제효과 주장

공정이용 판단 시 고려요소 순서에 따라 제1심법원과 항소법원의 판결 및 상고이유의 타당성을 검토한다.

1. 제1요소: 공정이용 규정 前文의 목적 예시와 제1요소의 '상업성'

상고이유는 항소법원이 제1요소의 예시인 '(피고이용의) 상업적 성질(commercial nature)'에 지나치게 큰 비중을 두어 판단하였다고 비판하였다. 그러나 실제로 항소법원은 제1요소를 판단할 때 피고 카탈로그의 상업적 성질에 큰 비중을 두지 않았다. 항소심판결이 피고 카탈로그의 상업성을 언급은 하였으나, 오히려 제1요소 판단의 결정적 요인은 '피고 카탈로그의 상업성'이 아닌 '변형성'이라는 점을 명확히 하였다.[50] 이 점에서 상고이유는 항소심판결을 과장 또는 오해하였다. 이 사건의 제1심판결과 항소심판결, 그리고 상고이유는 미국 연방저작권법 제107조 전문의 공정이용 목적 예시들과 제1요소 고려사항 예시(상업적 성질)가 공정이용의 취지에 반하여 주장·판단되는 모습을 잘 보여준다. 다음에서 살펴본다.

(1) 공정이용 목적 예시와 변형적 이용: 피고시장과 피고이용의 구별

미국 연방저작권법 제107조 전문에 열거된 예시(이하 '공정이용 예시')들은 ① 피고작품이 판매되는 '시장'이 아닌 ② 피고 '이용'의 목적을 뜻한다. 즉, ① 피고작품이 판매되는 시장이 '비평, 논평, 시사보도, 교육, 학문, 또는 연구 등 관련 시장'이란 뜻이 아니라, ② 원고저작물을 소재로 피고가 '비평, 논평, 시사보도, 교육, 학문, 또는 연구 등' 이용행위를 한 것을 뜻한다. 피고가 ②의 이용행위를 한 결과물이 ①의 시장에서 판매될 뿐이다. 그런데 이 사건과 같이 '공정이용 예시' 행위를 하지 않은 피고가 단순히 원고저작물을 복제한 후에 원고저작물의 현재 시장에서 원고저작물에 대한 수요를 직접적으로 대체하였음에도, 단지 피고작품이 팔리는 시장이 '공정이용 예시' 관련 시장이라는 이유만으로 '공정이용 예시'에 해당한다고 주장하는 사건을 종종 볼 수 있으며, 심지어 법원이 이를 인용하는 경우도 있다. 이 사건에서 원고 카탈로그는 피카소

50) '제르보스 카탈로그 사건'(주5), 225쪽. "[Commercial use] is "not conclusive … but rather a fact to be weighed along with others in fair use decisions." … The "central purpose" of considering the "purpose and character" of the work is to determine whether the new work is "transformative" ….." Campbell 사건(주15), 579쪽 인용.

작품에 관해서는 '바이블'로 통했으며, 피카소 작품 관련 일을 하는 누구든("수집가, 젊은 딜러, 도서관 등") 필요로 했다. 그러나 1978년에 발행된 원고 카탈로그 가격은 약 20만 달러의 고가였으며, 2014년에 발행된 개정판 가격도 약 2만 달러로서 높은 편이었다.[51] 이런 상황에서 점차 많은 딜러와 경매업자들은 권당 150달러인 피고 카탈로그를 이용하고 있었다.[52] 그러므로 원고 카탈로그와 피고 카탈로그에 대한 대부분 수요자들의 구매목적은 같았으며, 실제로 피고 카탈로그는 원고 카탈로그를 대체하는 경쟁상품이었다.

Leval 판사의 '변형적 이용 기준'은 피고가 공정이용 규정의 '공정이용 예시'를 '이용행위'가 아닌 '관련 시장'의 뜻으로 둔갑시키는 시도와 이에 따른 법원의 오판을 방지하는 기능을 가진다.[53] 상고이유는 '제107조 전문에 열거된 이용목적 예시에 해당하면 공정이용으로 인정'해야 한다는 근거로 제2연방항소법원의 'Wright 사건'을 제시하였다. 그러나 '변형적 이용 기준'을 적용하면, 'Wright 사건'과 이 사건은 성격이 다른 점이 명확해진다. 'Wright 사건'에서 법원은 피고작가가 그의 작품을 통하여 '비평 행위'를 하였다고 인정하였다.[54] 그러나 '제르보스 카탈로그 사건' 피고는 원고사진을 인용한 것이 아닌 단순 복제를 하였으며, 피고 카탈로그는 비평의 성격도 없고 기타 원고사진을 '공정이용 예시' 행위를 통하여 변형하지도 않았다.

(2) 피고이용의 상업적 성질

상고이유가 지적한 대로 피고 카탈로그의 '상업성'은 큰 비중을 두고 고려할 사항이 아니다. 왜냐하면 상당수의 변형적 작품은 상업적 목적을 가지고 있으며, 제1요소를 판단할 때 '상업성'에 큰 비중을 두면 결국 공정이용 규정이 사문화될 것이기 때문이다.[55] 결국 '상업성' 관련하여 피고작품이 '상업적'

51) Stolz(주8), Ibid.
52) George Stolz, "Authenticating Picasso", ARTnews, January 2, 2013.
53) 더 자세한 내용은, 이 논문 'IV. 제1요소와 다른 요소의 관계'.
54) Wright v. Warner Books, Inc., 748 F.Supp. 105, 108 (S.D.N.Y. 1990)('Wright 사건'(주33) 1심).
55) 미국 연방대법원의 입장이다: "If … commerciality carried presumptive force against a finding of fairness, the presumption would swallow nearly all of the illustrative uses listed in the preamble …, including news reporting, comment, criticism, teaching, scholarship, and research, since these activities "are generally conducted for

이 아닌 '비상업적'인 경우에만 고려하는 것이 공정이용 규정의 실효성을 확보하는 데 도움이 된다.[56] 그러나 공정이용 제1요소를 판단할 때, '비상업적 이용인 경우만 상업성을 고려한다는 것'과 '비상업적 이용의 비중을 어느 정도 반영할지'는 구별되는 문제이다. 사안에 따라 '비상업적 이용'의 비중을 크게 두고 제1요소를 판단하면 문제가 될 수 있다. 예를 들어, 피고가 공공기관이나 지자체 등이면 저작물 이용목적이 대부분 비영리적이고 공익목적일 수밖에 없는데, '비상업적 이용'에 큰 비중을 두고 제1요소를 판단하는 것은 공공기관이나 지자체가 고객인 저작물 시장을 없애는 결과가 될 우려도 있기 때문이다.[57]

저작권법은 2011년에 공정이용 규정을 신설할 때는 "보도·비평·교육·연구 등"을 공정이용 목적 예시로, "영리성 또는 비영리성 등"을 제1요소 고려사항 예시로, 열거하였다.[58] 그러나 2016년에 위 예시들을 삭제하였다.[59] 입법이유서는 삭제이유를 "저작물 이용 활성화라는 공정이용 규정의 목적달성"을 위한 것이라고 설명하였다.[60] 피고작품이 원고저작물로부터 변형적이지 않은 경우에도 피고작품이 위 '공정이용 예시' 시장에서 팔리고 있다는 이

---

profit in this country."" 'Campbell 사건'(주15), 1174쪽.

56) 이는 한국 저작권법 공정이용 규정을 해석할 때도 마찬가지다. 공정이용을 해석할 때 "영리성을 고려하지 않거나, 적어도 비영리성을 널리 인정"하자는 견해는, 이일호(주3), 앞의 논문, 177쪽.

57) 예를 들면, 최근 '소양강처녀 사건'이 있다. 이 사건에서 피고 지자체들은 고 반야월 선생이 작사한 〈소양강처녀〉 등 가요들의 가사를 기재한 노래비 등을 설치하였는데, 항소법원은 ① 원고 측 저작물을 관광명소에 설치된 노래비에 사용한 것은 노래 가사의 통상적 이용 방법인 악곡과의 결합 이용이나 가사집 게재 등과 충돌하거나 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해친다고 볼 수 없고, ② 피고의 이용은 비영리목적이었으므로 공공의 이익을 위한 목적이었고, ③ 저작자의 명예를 높이고 홍보에 용이한 환경을 조성하여 그 저작물의 잠재적인 가치에 긍정적 영향을 주었다는 점 등을 이유로 공정이용이라고 판단하였다. 서울중앙지방법원 2021. 1. 22. 선고 2019나28156,2019나45076 판결(이하 '소양강처녀')(대법원 2021다216872 계류 중). 이에 대해서는, 피고가 원고 측 저작물과 같은 감상 목적으로 원고 측 저작물 전부를 변형 없이 그대로 이용하였음을 이유로 위 판결을 비판한 견해가 있다. 손승우/권세진, "노래비 제작을 위한 저작물 이용의 공정이용 분석", 『스포츠엔터테인먼트와법』, 제25권 제1호, 한국스포츠엔터테인먼트법학회(2022), 124-125쪽. 최근 지자체들이 각종 축제 등에서 지자체 홍보수단으로 저작물 등 지식재산을 활용하는 경우가 늘어나고 있으며, 홍보의 주된 목적이나 효과는 그 지역의 경제적 수익 증가임을 고려하면, 위 비판은 타당하다고 본다.

58) [시행 2011. 7. 1.] [법률 제10807호, 2011. 6. 30., 일부개정]. 제35조의3 제1항과 제2항 제1호.

59) [시행 2016. 9. 23.] [법률 제14083호, 2016. 3. 22., 일부개정]. 제35조의3 제1항과 제2항 제1호.

60) 저작권법 일부개정법률안(대안), 의안번호 18606, 2016. 2. 29. 제안, 2쪽.

유만으로 공정이용이라고 주장하는 것을 어느 정도 방지하는 효과를 기대할 수 있다는 점과 '영리성·비영리성'을 고려하는 비중을 줄였다는 점에서 '저작물 이용 보호'뿐만 아니라 '저작권의 공정한 보호'에도 이바지하는 개정이었다고 본다.[61]

2. 제2요소: 저작물성·실질적 유사성의 창작성과의 구별과 입법이유

상고이유는 항소심판결이 '저작물성을 판단할 때 창작성'과 '공정이용 제2요소를 판단할 때 창작성'을 구별하지 못했다고 비판하였다. 공정이용 제2요소에 관하여 법원은 주로 원고저작물의 창작적 성질과 미공표 여부를 보는데,[62] 이 사건에서 원고사진은 공표되었으므로, 다음에서는 원고저작물의 창작적 성질에 관하여 논한다.

(1) 저작물성·실질적 유사성의 창작성과 공정이용의 창작성의 구별

저작권법에서 창작성(creativity)은 다음 세 단계에서 논의된다: ① '원고작품이 저작물인지를 결정하는 저작물성 판단 단계'; ② '원고저작물 중 피고작품과 유사한 부분에 창작성이 있는지를 결정하는 실질적 유사성 판단 단계'; ③ '실질적 유사성이 인정된 부분의 창작적 성질을 결정하는 공정이용(제2요소) 판단 단계.'[63] 이 사건에서 프랑스 제1심법원이 창작성을 부인한 것은 '저작물성 판단 단계'와 '실질적 유사성 판단 단계'였다. 그리고 피고는 원고사진

61) 이 개정에 대하여 "이용의 변형성을 고려할 수 있는 문언적 기반이 미국 법보다 오히려 우리 법에서 더 견실해 보인다."는 견해가 있다. 류시원(주2), 앞의 논문, 44쪽. 다만, 위 취지가 판결에는 적극적으로 반영되지 않는 것으로 보인다. 최근에 2012년 4월부터 현재까지 한국의 거의 모든 공정이용 판결(하급심 포함)에 대한 실증적인 분석에 따르면, 위 개정을 통하여 '영리성 또는 비영리성 등'이 삭제된 것은 "영리성이 있는 이용에 대해서도 공정이용을 인정할 것을 주문한 것"임에도 불구하고, 삭제 이후에도 법원은 여전히 영리성을 공정이용 판단의 중요한 기준으로서 고려하였다고 한다. 이일호(주3), 앞의 논문, 165-166, 177쪽.

62) 이 논문 'III.2. 제2요소: 저작물성·실질적 유사성의 창작성과의 구별과 입법이유'.

63) '실질적 유사성'뿐만 아니라 '의거관계'도 창작성 있는 부분에서 인정되어야 하므로, 엄밀히 말하면 '실질적 유사성 판단 단계'나 '실질적 유사성이 인정된 부분'보다는 '유사 부분의 창작성 판단 단계'나 '침해가 잠정적으로 인정된 부분'이 더 정확한 표현이다. 그러나 이 논문의 주제인 공정이용 판단은 실질적 유사성 인정이 전제라는 점을 부각하기 위해 '실질적 유사성' 표현을 쓴다.

을 변형 없이 전부 복제하여 경쟁상품인 피고 카탈로그에 실었으므로, 원고사진의 저작물성이 인정된 이상[64] 실질적 유사성 판단 단계에서의 창작성은 당연히 인정되며 쟁점이 안 된다. 그런데 이 사건과 같이 공정이용이 쟁점이라는 것은 실질적 유사성이 인정된 것을 전제로 한다. 그러므로 공정이용 제2요소의 저작물의 창작적 성질에 대한 판단은 실질적 유사성 판단 단계의 창작성 유무 판단 이상의 사항들을 고려하는 것이며, 공정이용 쪽으로 판단될 수도 있다. 그런데 항소법원은 단순히 원고사진에 창작성이 있다는 이유만으로 제2요소를 공정이용이 아닌 쪽으로 판단했다. 즉, 저작물성이나 실질적 유사성 판단 단계에서의 창작성 인정 근거만으로 공정이용 판단 단계에서 원고 저작물의 창작적 성질을 결정하였다. 이런 방식으로 결정하면, 실질적 유사성 인정을 전제로 하는 공정이용 판단 단계에서는 그 사안과 관계없이 제2요소는 항상 공정이용이 아닌 쪽으로 판단될 수밖에 없다. 그래서 상고이유가 "눈에 띄게 순환적인 분석(glaringly circular analysis)"이라며 비판한 것이다. 물론 항소법원은 제2요소를 공정이용이 아닌 쪽으로 결정했지만, 그 정도는 약하다고 판단하였다. 그러나 항소법원이 ① 원고사진의 저작물성 인정 근거로서의 창작성에 관한 언급만을 되풀이한 점, ② 원고사진의 창작적 성질이 약하다는 피고 주장에 답하지 않은 점, ③ 피고가 제출한 '원고사진들은 예술작품이 아니라는 저명한 미술사학자의 의견'에 답하지 않은 점을 고려하면, 항소법원은 사실상 공정이용 제2요소를 판단하지 않은 것이다.

(2) 제2요소 관련 입법이유

상고이유서가 인용한 제5연방항소법원의 'Compaq Computer 사건'과 제11연방항소법원의 'Cambridge Univ. Press 사건'은 '저작물성의 창작성'

64) '제르보스 카탈로그 사건'에서 원고사진의 창작성은 쟁점이 아니었다. 이는 외국(프랑스) 판결을 국내(미국)에서 강제하려는 것이 이 사건의 목적이었기 때문이라고 본다. 그러나 이 사건이 미국 또는 한국의 국내 사건이었다면 원고사진의 창작성이 주요 쟁점이었을 것이다. 프랑스에서도 제1심법원은 원고사진의 창작성을 부인했지만 항소법원은 그 창작성을 인정하는 등 주요 쟁점이었다. 미술작품을 사진으로 정확하게 복제한 화보집에 대하여는, "평면적인 회화를 그대로 사진촬영하는 것은 구도나 카메라 앵글의 설정, 조명의 강약 및 방향의 조절 등에 있어서 정신적·개성적 요소가 작용할 여지가 거의 없고, 인물의 증명사진과 마찬가지로 원작을 충실하게 기계적으로 재제(再製)하는 것에 불과하므로 창작성을 인정할 수 없다"는 견해가 통설이다. 오승종, 『저작권법』, 박영사(2020), 151쪽. 같은 취지: 박성호, 『저작권법』, 박영사(2017), 116쪽.

과 '공정이용 제2요소의 창작성'을 구별하였지만, 실제로 그 구별이 명확하지는 않다. 실제로 제2요소는 공정이용 판단에서 중요한 역할을 하지 않으며,[65] 제2요소를 다룬 입법이유도 찾기 힘들다. 제1요소 관련 변형적 이용 기준을 제시한 Leval 판사는 "제2요소는 피상적으로만 논의되었으며 이해된 것도 거의 없다."[66]고 평가하였다. Leval 판사는 제2요소는 Folsom v. Marsh 사건의 "value of the material used"[67]에서 따온 것이라고 주장하였지만,[68] 이는 Leval 판사가 오해한 것으로 보인다. 'Folsom 사건'의 해당 부분은 "nature, extent, and value of the materials thus used"인데,[69] 공정이용 제2요소에 해당하는 것은 'nature'이고, 'extent'와 'value'는 제3요소의 'amount'와 'substantiality'에 해당한다고 본다.

다행스럽게도, 간헐적으로 발견할 수 있는 제2요소에 관한 입법이유서는 제2요소가 무엇을 염두에 두고 제107조에 규정되었는지 짐작하게 한다. 미국 연방의회 저작권법 개정안에 대한 보고서들 중 공정이용 제2요소의 해석례를 수업목적복제와 관련하여 설명한 부분이 있어 소개한다(이하 '1967년 하원보고서'):[70]

시장

> **원고저작물의 성격**(character of the work) - 예를 들면, 교사가 수업목적으로 신문에서 기사 '하나'를 복제하는 것과 오케스트라 곡 '전부'를 복제하는 것은 다르다. 일반적으로 뮤지컬, 드라마, 영화와 같은 시청각저작물 등 공연할 의도로 만든 작품 '전부'를 복제하는 경우에는 공정이용법리를 엄격하게 적용할 것이라 예상된다. 또한 교사와 학생들이 이용한

65) "…, the second factor has rarely played a significant role in the determination of a fair use dispute." William F. Patry, Patry on Fair Use § 4:1 (May 2022 Update). Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. of America, 659 F.2d 963, 972 (9th Cir. 1981), rev'd on other grounds, 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2d 574 (1984)와 Sony Computer Entertainment America, Inc. v. Bleem, LLC, 214 F.3d 1022, 1029 (9th Cir. 2000) 인용.

66) "only superficially discussed and little understood." Pierre N. Leval, Toward A Fair Use Standard, 103 HARV. L. REV. 1105, 1116 (1990).

67) Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342, 344 (C.C.D. Mass. 1841)(이하 'Folsom 사건').

68) Leval(주66), Ibid., 1117쪽.

69) 'Folsom 사건'(주67), 344쪽.

70) H. R. REP. No. 83, 90th Cong., 1st Sess. at 34 (1967). 인용 부분의 작은따옴표는 저자가 추가.

원고저작물이 워크북, 연습문제, 표준화된 테스트, 해설지 등 교실에서 쓰이도록(consumable) 의도해서 만든 것이라면, 공정이용은 거의 인정되지 않을 것이다. 교과서 등 주로 교육시장에서 판매할 목적으로 만든 것도 다른 종류의 상품에 비해 공정이용이 인정되기 힘들 것이다. 교과서를 보완하고 업데이트할 목적으로 신문이나 정기간행물의 시사적인 콘텐츠를 이용하는 것은 공정이용을 폭넓게 인정해야 하지만, 그 정기간행물이 주로 학생을 대상으로 출판된 것이라면 공정이용을 인정하기 힘들다.

원고저작물의 이용가능성(availability of the work) - 원고저작물이 절판(out of print)되어 통상적인 방법으로 구할 수 없다면 공정이용으로 인정될 가능성이 크지만, 합리적인 가격에 절판된 저작물을 판매할 권한을 가진 단체가 존재하는지도 고려하여야 한다. 원고저작물이 미공표저작물(unpublished works)인 경우도 구할 수 없기는 마찬가지지만, 이는 원고가 의도적으로 선택한 결과이기 때문에 공정이용으로 인정되기 힘들다. 일반적으로 저작권자의 최초발행권(right of first publication)이 수업목적으로 복제할 필요에 우선할 것이다.

피고는 상고이유서에서 '원고사진은 주로 피카소 그림의 외관에 관한 사실적 정보를 전달'하기 때문에 약한 보호를 받을 수밖에 없다는 점을 이유로 제2요소는 공정이용 쪽으로 기운다고 주장하였다. 원고사진이 사실적 정보를 전달한다는 점은 설득력이 있다. 우선 원고 카탈로그와 같은 '카탈로그 레조네'는 프로비넌스와 함께 작품의 진위 판명이 주요 기능이다. 또한 원고사진은 컬러가 아닌 흑백이었는데, 이는 '부정확한 컬러사진보다는 잘 찍은 흑백사진이 작품을 더 있는 그대로 나타낼 수 있다.'고 생각한 피카소가 강하게 요구하였기 때문이라고 한다.[71] 그리고 정보를 전달하는 사실적 저작물과 엔터테인먼트 성격의 非사실적 저작물을 구별하여 제2요소를 판단하는 입장도 있다. 위 입장은 원고저작물이 사실적 또는 기능적 성격을 가졌으면 제2요소를 공정이용 쪽으로 판단한다.[72] 그러나 앞서 소개한 입법이유는 제2요소 관련하여

71) "… in Picasso's view, a good black-and-white reproduction was more truthful to the work than an inaccurate color photograph." Stolz(주8), Ibid.
72) Patry(주65), Ibid., § 4:1.

일반적으로 정기간행물 기사를 수업목적으로 이용한 것을 공정이용 쪽으로 판단하면서도, 수업목적 또는 학생을 대상으로 발행한 정기간행물의 경우에는 공정이용이 아니라고 하였다. 또한 워크북과 같이 처음부터 교실에서 쓰일 것을 목적으로 생산된 소모품에 공정이용을 인정하면, 교육용 소모품 시장은 파괴될 것이다.[73] 같은 취지를 적용하면, 이 사건 원고사진은 피고 주장대로 사실을 전달하는 성격이 강하지만, 피고는 처음부터 '카탈로그 레조네 용도'로 찍은 원고사진을 원고 카탈로그와 같은 '피카소 작품의 카탈로그 레조네'에 같은 방식으로 이용하였으므로, 제2요소는 공정이용이 아닌 쪽으로 '강하게' 기운다고 본다. 이 점에서 공정이용이 아닌 쪽으로 판단하였지만 그 정도를 '약하게' 본 제1심판결과 항소심판결도 비판의 여지가 있다. 이와 같이 원고저작물의 '창작성이 약한' 경우에도 공정이용 제2요소는 공정이용이 '아닌 쪽으로 강하게' 판단할 수 있으므로, 저작물성·실질적 유사성의 창작성과 공정이용 제2요소의 창작성은 구별된다.

그런데, '1967년 하원보고서'의 예시를 보면, 제2요소를 판단할 때 '절판'이나 '미공표 여부' 등 '원고저작물의 이용가능성'은 '원고저작물의 성질'만을 고려하고 있다. 그러나 위 보고서는 제2요소의 예시를 설명하면서 '원고저작물의 성질'뿐만 아니라 '교실에서의 이용'도 고려하였는데, 이는 제1요소인 '피고이용의 목적과 성격'도 함께 판단한 것처럼 보인다. 다음에서 논의한다.

IV. 제1요소와 다른 요소의 관계

공정이용 여부를 판단할 때 미국 법원은 요소별로 공정이용 또는 非공정이용이라고 결론 내린 후, 이를 종합하여 최종 결론을 내리는 방식으로 판결문을 작성한다. 그러나 각 요소를 따로 판단하더라도, 사실상 각 요소는 서로 연관되므로 다른 요소를 고려하지 않고 개별 요소를 따로 판단하기는 힘들다. 그 이유를 설명한다.

73) Willliam F. Patry, The Fair Use Privilege in Copyright Law 429 (1985).

1. '변형적 이용'의 의미와 기능

우선 제1요소를 공정이용 쪽으로 판단하는 근거(justification)로서 '변형성(transformative)'을 제시한 Leval 판사에 따르면, '변형적'이란 원고 저작물이 다른 방식(different manner) 또는 다른 목적(different purpose)으로 이용됨으로써 '생산적(productive)'이라고 볼 수 있는 상황을 의미한다.[74] 예를 들면, 피고작품이 원고저작물을 단순히 재포장하거나 재발행하는 등 원고저작물을 단순 대체하는 경우에는 변형적 이용이 아니다.[75] 반대로, 피고가 원고저작물을 재료(raw material)로 삼아 새로운 정보, 미감, 통찰과 해석(information, aesthetics, insights and understandings) 등 새로운 가치를 부여하였다면, 이는 공정이용이 보호하려는 바로 그 유형(the very type)의 행위에 해당한다.[76]

Leval 판사 주장의 전제를 요약하면 다음과 같다. 우선 Leval 판사는 저작권은 저작자가 필연적으로 가지는 절대적 권리, 신성한 권리 또는 자연권(inevitable, divine, or natural right)이 아니라고 하였다. 반대로 저작권은 "예술 분야의 활동과 발전을 자극함으로써 공중을 지적으로 풍요롭게 하려는(intellectual enrichment of the public)" '실용적인 목적(utilitarian goal)'을 위하여 고안된 것이며, 이를 위하여 창작적 노력에 대한 보상을 받도록 저작자에게 허용된 것(permitted)이라고 보았다.[77] 그러나 모든 지적 창작 활동은 기존의 창작물을 2차적으로 활용하는 것이므로, 지식재산을 지나치게 보호하면 창작 활동을 자극하지 않고 오히려 억누를 수 있다.[78] 이 문제를

74) Leval(주66), Ibid., 1111쪽.

75) 위 논문, 같은 쪽. Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342, 345 (C.C.D. Mass. 1841)의 Story 판사 의견 인용.

76) 위 논문, 같은 쪽.

77) 위 논문, 1107-1100쪽. 그리고 미국 연방대법원의 일관된 판결과 미국 헌법 제8조, 앤여왕법 등을 근거로서 제시하였다. 위 문헌들에 관한 설명은 국내에 많이 소개되었으므로 생략한다. 한편, Leval 판사 견해에 대한 비판은, 조채영, "공정이용과 동일성유지권의 충돌에 관한 연구: 현대예술에서 독창성의 의미와 차용예술을 중심으로", 연세대학교, 박사학위논문(2016), 311-312쪽(공정이용을 판단할 때 "공리주의적 관점에서 공익적인 목적을 이유로 재산권 침해적 이용행위가 정당화될 수 없다"는 Lloyd L. Weinreb 교수 견해 인용).

78) 이 문제를 정확히 설명한 견해가 있다. "이미 … 동일한 또는 유사한 표현이 있었다는 사실만으로 표현하고자 하는 의욕을 포기하거나 다른 표현을 하고자 노력하여야 한다면, … 실질적

해결하기 위하여 미국 사법부는 '아이디어와 사실을 저작권으로 보호하지 않는다는 원칙'을 만들었다. 그리고 2차적 창작을 보호하는 공정이용법리를 만들었는데, 이는 저작권 보호의 취지에 부합한다.[79]

한편 저작자는 자신의 저작물을 이용한 2차적 창작을 금지할 수 있는 2차적저작물작성권을 가진다. 따라서 Leval 판사와 같이 공정이용법리의 기능을 '2차적 창작의 보호'라고 본다면, 공정이용법리의 주요 기능은 피고이용이 2차적저작물작성권 침해인지, 아니면 공정이용인지를 구별해 내는 것이 된다.[80] 그러므로 피고가 원고저작물에 '새로운 정보, 미감, 통찰과 해석 등'[81] 또는 '새로운 표현, 의미, 메시지 등'[82]을 부여하였다는 사정만으로 이를 공정이용이라고 판단할 수는 없고, 그 정도를 고려하여야 한다. 왜냐하면, 피고가 부여한 '새로운 표현, 의미, 메시지 등'의 정도가 미미함에도 불구하고 '공정이용'을 인정한다면, 저작자의 2차적저작물작성권이 사실상 무력화될 수 있기 때문이다.[83]

유사성 이론 또는 판단 기준은 사실상 표현의 자유 제한의 한 수단이라고 말할 수 있다." 계승균, "저작권과 표현의 자유", 『산업재산권』, 제69호, 한국지식재산학회(2021), 235쪽. 다만, 실질적 유사성 기준은 법원이 적용하기에 따라서 이용자의 표현의 자유를 억압할 수도 있지만 반대로 보호할 수도 있다고 본다. 예를 들면, 대법원 2014. 8. 26. 선고 2012도10786 판결(이하 'Be the Reds 사건')(피고인이 피해자 저작물을 부수적으로 이용한 경우에는 실질적 유사성을 부인함)과 대법원 2017. 11. 9. 선고 2014다49180 판결(이하 '짝 사건')(원고 리얼리티프로그램 포맷을 이용하여 원고영상물을 희화화한 피고영상물이 그 성격, 등장인물, 구체적인 사건의 진행과 내용 및 구성 등에서 표현의 차이가 상당하다는 이유로 실질적 유사성을 부인함).

79) "…, the fair use doctrine, which protects secondary creativity as a legitimate concern of the copyright." Leval(주66), Ibid., 1109-1110쪽.

80) 실제로 '공정이용에 해당하지만 2차적저작물이라는 이유로 공정이용을 부인'한 판결은 단 한 건도 없었다. Patry(주65), Ibid., § 6:16. Fair use and the right to prepare derivative works, 주2에 해당하는 본문의 다음 문장. 한편, 2차적저작물작성과 변형적 이용(또는 공정이용)은 서로 다른 층위에 있으므로, "2차적저작물작성에 해당한다는 점은 공정이용을 배제하는 근거가 아니라, 공정이용판단의 전제가 되어야 한다."는 견해가 있다. 류시원(주2), 앞의 논문, 40쪽. 피고가 원고저작물의 창작성 있는 부분에 창작적 표현형식을 추가하였으나 2차적저작물작성에 해당하지 않는다면, 이는 법원이 '원고저작물과의 실질적 유사성'을 부인하였다는 의미다. 그렇다면 공정이용 판단의 전제가 성립하지 않는다. 일단 법원이 실질적 유사성을 인정하고 잠정적으로 복제권이나 2차적저작물작성권 등 저작재산권 침해를 결정하여야, 공정이용 판단 단계로 나아갈 수 있다는 점에서, 2차적저작물작성이 공정이용판단의 전제라는 위 견해는 타당하다.

81) Leval(주66), Ibid., 1111쪽.

82) 'Campbell 사건'(주15), 579쪽.

83) 'Warhol 사건'(주2), 1282쪽. 관련하여, 연방대법원은 피고의 의도나 비평가의 느낌을 기준으로 '변형적 이용 여부'를 판단한다면 모든 변경이 '변형적'이 될 것이므로, 제1요소 판단은 '피고의 원고저작물 이용형태'에 기초한 '객관적 조사(objective inquiry)'여야 한다고 하였다. 위 사건,

또한, 위에서 설명한 Leval 판사의 논거는 피고가 원고저작물에 창작적 표현형식을 추가하지 않고 2차적으로 활용하는 상황에도 적용할 수 있다. 예를 들면, 정보전달을 위한 썸네일 이미지를 제작하는 경우와 같이 피고가 원고저작물에 창작적 표현형식을 추가하지 않은 경우에도 피고 썸네일 이미지를 표현의 자유로 보호할 필요가 있다. 이 경우 피고의 표현의 자유를 원고의 표현의 자유보다 우선하기 위하여 법원은 실질적 유사성을 부인하거나 공정이용을 인정할 수 있다. 이는 궁극적으로는 저작자를 보호하는 표현의 자유와 이용자를 보호하는 표현의 자유를 비교형량하는 과정이다.[84]

2. 제1요소와 제2요소의 관계와 변형적 이용

다시 '변형적 이용'으로 돌아와서, 제1요소를 판단할 때 피고이용이 '변형적'이었는지를 결정하려면, 굳이 Leval 판사의 논문을 인용하며 법리나 이론을 들이대지 않더라도, 상식적으로 원고저작물과 피고작품을 대비하여 그 차이를 관찰하는 과정이 필요하다. 그러므로 공정이용의 제1요소(피고이용의 목적과 성격)를 판단할 때는 제2요소(원고저작물의 성질)와 대비하여 판단할 수밖에 없고 따로 판단하는 것은 힘들다. Leval 판사 스스로 밝혔듯이, 이미 1740년 잉글랜드의 Gyles v. Wilcox 사건[85]과 1841년 'Folsom 사건'에서도[86] ('변형적'이라는 표현은 사용되지 않았지만) 변형적 이용의 중요성은 강조되었다.[87] 위 판결들에서도 원고저작물(original work)과 피고작품(abridgements)을 대비하였는데, 이는 저작권(뿐만 아니라 모든 지식재산권) 침해를 판단할 때 필연적으로 거치는 과정이다.

1284쪽.

84) 예를 들면, "성공한 패러디는 저작물로서 성립되어 새로운 저작권이 발생하…지만, 실패한 패러디는 표절을 추정케 하고 저작권침해가 되는지 여부를 심사하여야 한다." 계승균(주78), 앞의 논문, 233쪽.

85) 26 Eng. Rep. 489, 2 Atk. 141 (1740). 이 사건에 관한 자세한 내용은, 신동룡, "18세기 영국에서의 '공정하고 선의의 요약 원리'에 대한 연구", 『계간저작권』, 제109호, 한국저작권위원회(2015), 76-78쪽.

86) 'Folsom 사건'(주67)에 관한 자세한 내용과 그 영향은, 권세진, "저작권 침해의 구성요건으로서 공정이용 법리의 역사적 고찰", 『산업재산권』, 제46호, 한국지식재산학회(2015), 139-144쪽.

87) Leval(주66), Ibid., 1112쪽.

3. 제2요소의 독자적 존재 의의

'제르보스 카탈로그 사건'의 항소법원은 제2요소는 ① 원고저작물의 창작성 정도와 ② 미공표 여부라는 두 측면을 고려하는 것이라고 하였다. 그리고 제1심법원과 항소법원은 공정이용이 아닌 쪽으로 판단하고 그 정도는 약하다고 하였다. 그러나 제1요소에서 변형적인지를 판단할 때 제2요소인 '원고저작물의 성질'까지 필연적으로 고려할 수밖에 없다면, 제2요소를 공정이용 판단의 요소로서 저작권법에 별도로 열거할 필요가 있는지 의문이다.

우선 원고저작물의 창작성 정도와 관련하여, 예를 들어 피고작품이 원고저작물을 비평하기 때문에 변형적이면(제1요소), 비평의 대상인 원고저작물이 창작성이 큰 소설이든 창작성이 작은 기록물이든 제2요소가 공정이용의 최종 판단에 미치는 영향은 찾기 힘들다. 반대로 변형적 이용이 부인되어 제1요소가 공정이용이 아닌 쪽으로 판단된 경우에도, 원고저작물의 창작성이 크든 작든 최종 판단에 미치는 영향은 찾기 힘들다. 예를 들어 '제르보스 카탈로그 사건'에서 비록 원고사진의 성질이 사실적인 기록물이기 때문에 창작성이 약하다고 해도, 피고가 원고사진을 원고 카탈로그와 같은 목적으로 똑같이 복제하였기 때문에 변형적 이용이 부인되어 제1요소가 공정이용이 아닌 쪽으로 판단된다면, 제2요소가 공정이용의 최종 판단에 미치는 영향은 없다. 다만, 이 사건에서와 같이 원고저작물의 창작적 성격이 약하다면, 피고작품의 목적이나 용도가 원고저작물로부터 조금만 달라져도 변형적 이용이 인정될 수 있을 텐데,[88] 이 경우도 제2요소를 제1요소와 별개로 판단할 실익은 없다.

또한 공정이용 제2요소를 판단할 때 원고저작물의 미공표 여부를 고려하는 것이 타당한지도 의문이다. 물론 미공표저작물도 저작권으로 보호받지만, 공표된 저작물에 비하여 저작권법의 목적 달성에 기여하는 정도가 일반적으로 작다는 점과 미공표저작물에 대해서는 공표권(한국) 또는 프라이버시권(미국)이라는 공정이용과는 다른 수단으로 보호된다는 점을 고려하면, 원고저작물의

88) 이는 실질적 유사성 판단에서도 마찬가지인데, 실질적 유사성이든 공정이용이든 피고이용의 위법성을 판단하는 과정이고, 위법성 판단은 결국 원고 권리가 피고이용에 미치는 범위를 정하는 문제이므로, 창작성이 약한 원고저작물은 약한 보호(thin protection)를 받는다는 원리는 실질적 유사성과 공정이용을 판단할 때 모두 적용된다.

미공표 여부를 공정이용 판단에서까지 고려할 실익은 없다고 본다.[89]

앞으로 공정이용을 판단할 때 제2요소가 제1요소의 변형적 이용 판단과 구별되는 독자적인 존재 의의를 가지는 상황이 생길 가능성도 있지만, 추후 저작권법 제35조의5 제2항 제2호의 삭제를 주기적으로 검토할 필요가 있다.

4. 제3·4요소와의 관계, 그리고 표현의 자유

틀린해석으로 보인다.

제1요소 판단 기준인 '변형적 이용'은 제2요소를 고려하지 않으면 판단할 수 없다. 또한 법원이 제1요소에서 피고이용이 '변형적'이라고 판단하면, 원고저작물과 피고작품은 질적으로 서로 다른 저작물이고(제3요소), 따라서 피고작품이 원고저작물 시장에 영향을 미치기 힘들어지므로(제4요소) 두 요소 모두 공정이용이 아닌 쪽으로 판단될 가능성이 커진다. Leval 판사도 그의 논문에서 '피고작품이 원고저작물을 단순히 재포장하거나 재발행하는 등 원고저작물을 단순 대체하는 경우에는 변형적 이용이 아니'라고 하였는데,[90] 이는 제1요소 판단을 위해 변형적 이용인지를 판단할 때 제3·4요소까지 고려하는 것이 필요함을 보여준다.[91]

'Warhol 사건'에서 연방대법원도 '제1요소와 제4요소는 같은 방향으로 결정될 가능성이 매우 크다(positive association).'고 설명하였다. 즉, 피고이용의 목적과 성격이 다르면 다를수록, 원고저작물에 대한 수요를 잠식할 가능성도 작을 것이라고 하였다.[92] 그리고 '제1요소는 피고이용(secondary use)

89) Leval 판사도 같은 맥락에서 '미공표저작물'을 공표로부터 보호하는 적절한 수단은 저작권법이 아닌 프라이버시법이라고 하며, 원고저작물이 '미공표저작물'이었던 점을 공정이용 제2요소 판단에서 고려하는 것이 적절한지에 대해 의문을 제기하였다. Leval(주66), Ibid., 1119쪽.

90) 위 논문, 1111쪽.

91) 공정이용 제3요소와 제4요소가 제1요소 결정에 미치는 영향을 구체적인 판례를 근거로 분석한 논문은, 조채영, "미국 저작권법상 공정이용 요건 중 변형성과 잠재적 시장에 미치는 효과의 판단 기준에 대한 판례 검토", 『과학기술과법』, 제11권 제2호, 충북대학교 법학연구소(2020). 이 논문은 주로 미국 제2연방항소법원 판결들을 분석하였다. 특히 제4요소의 잠재적 시장에 미치는 영향 관련하여, 피고가 원고에게 이용료를 지급하지 않았다는 사실만을 근거로 제4요소를 공정이용이 아닌 쪽으로 판단한다면, 제4요소는 언제나 공정이용이 아닌 쪽으로 결정될 것임을 지적한 판결들('Bill Graham Archives 사건'(주49); American Geophysical Union v. Texaco, 60 F.3d 913, 929 n17 (2d Cir. 1995))을 제시하며, "저작권자에게 시장의 통제권을 부여하면 저작권자가 시장의 진입 여부를 결정함으로써 새로운 시장의 형성 기회를 박탈"할 수 있어 공정이용의 존재 의미가 퇴색될 수 있음을 우려하였다. 위 논문, 369-370쪽.

의 목적이 원고저작물(original work)의 목적을 대체하는지와 그 정도를 고려'하는 반면, '제4요소는 실제 또는 잠재적 시장을 대체하는지에 초점'이 있다며 그 차이점도 설명하였다. 따라서 제1요소를 판단할 때는 피고이용이 원고에게 경제적 피해를 주었는지는 고려하지 않는다고 하였다.[93]

반대로 제4요소를 판단하려면 원고가 자신의 저작권을 이용하여 피고시장에서 이윤을 창출하는 것을 저작권법이 허용할지를 먼저 판단하여야 하는데, 이는 제1요소의 변형적 이용 판단이다. 법원이 이윤창출을 허용하려면 변형적 이용을 부인하여 피고작품을 원고저작물의 복제물 또는 2차적저작물로 만들 것이고, 이윤창출을 불허하려면 변형적 이용을 인정하여 피고작품을 원고저작물과 별개의 저작물 (또는 별개의 非저작물)로 만들 것이다. 그리고 그 과정에서 법원은 '권리자의 독점권을 부인하여 창작의욕이 감소될 위험'과 '권리자의 독점권을 허용하여 2차 창작 활동(또는 정보생산 활동)이 감소될 위험' 사이의 균형을 찾는다.[94] 이는 결국 권리자의 창작의욕을 장려하는 표현의 자유와 이용자의 (창작을 포함한) 정보생산의욕을 자극하는 표현의 자유를 비교형량하는 과정이다.[95] 그러므로 권리자의 표현의 자유와 이용자의 표현의 자유는 서로에게 '창작 또는 정보생산 비용'의 부담을 안긴다.

'차용미술 창작'은 위 비교형량과 창작비용 배분에 관한 논의가 필요한 대표적인 경우인데, 'Warhol 사건'에서 연방대법원은 '피고의 차용미술이 원고의 2차적저작물작성권 침해인지 공정이용인지'에 관하여 일종의 지침을 제시해 준다. 연방대법원은 Andy Warhol의 'Orange Prince'가 '가수 프린스에 관한 이야기를 전달'하는 것에 이용된 것은 Goldsmith의 프린스 사진과 '이

92) 'Warhol 사건'(주2), 1279쪽 주12. 'Campbell 사건'(주15), 591쪽 인용.
93) 'Warhol 사건'(주2), 1279쪽 주12.
94) 조채영(주91), 앞의 논문, 371쪽.
95) 다만, 이 작업은 사안에 따라 '공정이용 판단'에서 이루어질 수도 있고, '실질적 유사성 판단'에서 이루어질 수도 있다. 예를 들면, 원고저작물의 창작성이 약한 경우에는 공정이용을 인정하는 것이 아닌 실질적 유사성을 부인함으로써 저작권 침해를 부인할 수 있다. '짝 사건'(주78). 또한 피고가 원고저작물을 부수적으로 이용한 경우, 법원은 저작재산권 침해가 아니라는 판결을 위해 실질적 유사성을 부인할 수도 있고('Be the Reds 사건'(주78)), 실질적 유사성을 인정한 후에 공정이용을 인정할 수도 있다. 비슷한 취지: 문건영, "미술저작물등의 부수적 이용에 관한 연구: 대법원 2014. 8. 26. 선고 2012도10786 판결(Be the Reds 사건)을 중심으로", 『계간저작권』, 제125호, 한국저작권위원회(2019), 161쪽. 그러므로 저작자와 이용자를 보호하는 표현의 자유의 충돌은 공정이용뿐만 아니라 실질적 유사성 판단까지 모두 연결하여 해결하여야 한다.

용의 목적과 성격'이 거의 같으므로 변형적이 아니며 제1요소는 공정이용이 아닌 것으로 판단하였다.[96] 반면, 'Orange Prince'가 Warhol 관련 기사에 이용되었다면, 공정이용으로 판단될 수 있다.[97] 같은 원리를 적용하면 Warhol이 'Orange Prince'를 미술작품으로서 전시하는 행위도 공정이용에 해당할 것이다. 이는 원고저작자의 수요를 대체하는 차용미술 이용을 금지하면서도(2차적저작물작성권 침해) 동시에 차용미술의 창작 및 전시 행위는 침해가 되지 않도록 함으로써(공정이용), 차용미술 창작(2차 창작)을 위한 표현의 자유를 보장할 수 있는 가능성을 보여준다. 비록 연방대법원은 'Orange Prince'의 창작과 그 전시가 공정이용인지는 판단하지 않았지만, 공정이용이 될 수 있는 여지를 남겨 놓음으로써 차용미술 창작의 자유를 보장할 수 있는 길을 열어 놓았다고 본다. 앞으로 더 적극적인 관찰과 법리 개발이 필요한 부분이다.[98]

5. 논의의 정리

'제르보스 카탈로그 사건'에 나타난 문제점들을 토대로 지금까지 논의한 바를 정리한다.

첫째, 공정이용은 창작성(아이디어-표현 이분법), 실질적 유사성과 함께 저작자를 보호하는 표현의 자유와 이용자(2차 창작자 또는 정보생산자)를 보호하는 표현의 자유를 비교형량하는 기능을 가진다. 저작자의 표현의 자유와 이용자의 표현의 자유는 서로에게 창작 (또는 정보생산) 비용을 부담시키므로, 결국 창작성, 실질적 유사성, 공정이용 판단은 저작자와 이용자 사이에 위 비용을 어떻게 배분할지의 문제이다. 최근 'Warhol 사건'에서 연방대법원은 차

96) 'Warhol 사건'(주2), 1278-1279쪽.
97) 위 사건, 1279쪽 주12.
98) 관련하여, 박경신, "차용미술의 저작권법상 허용범위의 미적 판단 기준: 절차적 기준 정립을 중심으로", 『계간저작권』, 제129호, 한국저작권위원회(2020)(차용미술이 2차적저작물작성권 침해인지 공정이용인지 판단하려면 사법부가 미적 판단을 해야 한다는 것을 전제로 관련 미학이론과 필요한 절차적 기준을 제시함); 이상정, "차용미술(appropriation art)과 저작권", 『서울법학』, 제18권 제1호, 서울시립대학교 법학연구소(2010)(차용미술의 저작권 침해를 해결하기 위하여 일종의 법정허락제도를 제안함); 조채영(주77), 앞의 논문, 311-312쪽(차용예술이 저작권침해인지를 판단하는 기준으로서 원저작물의 감흥이 그대로 전달되는지를 제시함) 등이 있다.

용미술에 관하여 위 표현의 자유의 비교형량과 창작비용 배분의 문제를 해결할 가능성을 보여주었다.

둘째, 제1요소의 변형적 이용을 판단하려면 필연적으로 제2요소(원고저작물 성질)를 고려할 수밖에 없다. 반면, 제2요소 고려사항이라는 '창작적 성질'과 '미공표 여부'는 각각 제1요소와 별개로 판단할 실익이 없거나, 저작재산권에서 다룰 법익이 아니다. 특히 '미공표 여부'에 관하여, 한국은 공정이용 규정(제35조의5)이 저작인격권에는 적용되지 않으며, 미공표저작물의 공표에 저작인격권인 공표권을 적용할 수 있다. 따라서 제2요소는 앞으로 공정이용 판결이 쌓임과 함께 독자적인 존재 의의가 있는지 관찰하여 추후 공정이용 규정에서 삭제하는 것을 검토할 필요가 있다.

셋째, 제1요소와 제3·4요소는 분리하여 판단할 수 없으며, 각 요소를 판단할 때 다른 요소를 고려하지 않을 수 없다. 반면, 공정이용 판단에서 종종 피고는 ① 피고이용이 비평·논평·시사보도·교육·학문·연구 등 목적이라든지 ② 원고저작물의 창작성이 작다고 주장하고, 반대로 원고는 ③ 피고이용이 영리목적이라고 주장한다. 위 주장에 대하여 '제르보스 카탈로그 사건' 법원(특히 제1심법원)과 같이, 개별 요소 사이의 관계를 검토하지 않고 하나의 요소 또는 측면만을 이유로 각 요소의 결론을 내리면, 원고저작물과 피고작품이 같은 시장에서 경쟁하는 상품임에도 공정이용이라거나, 반대로 전혀 다른 상품임에도 공정이용이 아니라는 결론을 내릴 수 있다. 'Warhol 사건'에서 연방대법원도 '공정이용의 각 요소들은 다른 요소들과 '따로'가 아닌 '함께' 고려한 후에, 이를 취합하여 저작권법의 목적에 부합하는 최종 결론을 내려야 한다.'고 하였다.[99] 그러나 '제르보스 카탈로그 사건'에서와 같이 일부 사건 당사자들이나 하급심 법원들은 고려요소들을 유기적으로 판단하지 않고 단순 취합하여 공정이용을 주장하거나 판단하는 모습을 보일 때도 있다. 그러므로 고려요소들을 모두 '유기적으로' 고려하여야 한다는 것을 공정이용 규정에(또는 대법원이 공정이용 판단방법으로써) 명시할 필요가 있다. 이런 관점에

99) "The Court has cautioned that the four statutory fair use factors may not "be treated in isolation, one from another. All are to be explored, and the results weighed together, in light of the purposes of copyright." 'Warhol 사건'(주2), 1287쪽. 'Campbell 사건'(주15), 578쪽 인용.

서 본다면, '변형적 이용'을 굳이 제1요소의 판단 기준으로 한정할 필요가 있는지 의문이다. 오히려 '공정이용이란 변형적 이용을 의미하며, 그 판단을 위해 제1요소부터 제4요소까지 전부 고려하는 것'이라는 법리 구성도 가능하다. 이렇게 이해하면 제1요소부터 제4요소 중 어느 것이 가장 중요한지 논하는 일은 더 이상 의미가 없게 된다.

V. 결론: 제1요소와 변형적 이용 기준의 중요성

Leval 판사는 '제1요소는 공정이용의 영혼(soul)'이고, 제1요소에서 피고이용이 변형적이 아니라고 판단되면 다른 요소들을 판단하지 않고 공정이용이 아니라는 최종 결론을 내려야 할지도 모른다고 하였다.[100] 여기서 Leval 판사의 견해를 오해하면 안 된다. '제1요소가 결정되면 나머지 요소는 판단할 필요가 없을지도 모른다'는 의견은 제1요소가 결정되면, 나머지 요소가 모두 반대로 결정되어도 제1요소에 따라 최종 결론을 내려야 한다는 의미가 아니다. 제1요소의 '변형성'을 결정하려면 필연적으로 나머지 요소들도 종합적으로 고려해야 하기 때문에 특별한 사정이 없는 한 나머지 요소들도 제1요소와 같은 결론이 나올 가능성이 크다는 의미이고, 이것이 제1요소가 나머지 요소보다 중요한 이유다. 그러나 위에서 설명하였듯이, '변형적 이용 기준'의 의미를 제1요소의 판단 기준을 넘어 확장시키는 방법도 있다. 즉, '공정이용'이란 '변형적 이용'을 의미하며, 변형적 이용을 판단할 때 제1요소부터 제4요소까지 모두 고려하는 것이 더 좋은 해석방법일 수도 있다.

침해를 판단할 때 원고상품과 피고상품을 대비하여 그 차이를 검토하는 것은 저작권법뿐만 아니라 모든 지식재산권 침해 판단에서 필연적으로 거쳐야 하는 과정이다. '변형적 이용' 기준은 Leval 판사가 처음으로 고안한 것이 아니다. Leval 판사 스스로 밝혔듯이 저작권 침해를 판단할 때 피고작품과 원고저작물의 관계를 검토하는 것은 18세기 잉글랜드 판결에서도 찾아볼 수 있다. Leval 판사는 이 당연한 저작권법의 조리(條理)에 '변형적 이용'이라는 이름

100) Leval(주66), Ibid., 1116쪽.

을 붙임으로써, 법원들이 공정이용에 관하여 일관된 결론을 내릴 수 있도록 법적인 도구를 마련해 준 것이다.[101] '변형적 이용 기준'을 미국 연방대법원이 이례적으로 빠르게 받아들인 것도,[102] 그 내용이 저작권법의 원리에 충실하고 이미 그 원리에 따라 판결해 왔기 때문이라고 본다. 저작권법의 취지에서 벗어나지 않게 공정이용을 판단할 수 있는 편리한 도구를 법원에 제공하였다는 점에서 Leval 판사는 실로 지대한 공헌을 했다.

101) Leval 판사가 논문을 쓴 목적은 "공정이용에 적용할 수 있는 일관된 원리가 있으며, 이는 저작권법의 목적에 기초하고 있음을 밝히는 것"이다. Leval(주66), Ibid., 1105쪽.

102) Leval 판사 논문이 발표된 후 미국 연방대법원의 첫 번째 저작권법 공정이용 사건에서 '변형적 이용' 기준이 받아들여졌는데('Campbell 사건'(주15), 579쪽), 이는 논문이 발표된 후 불과 4년 만이다.

Abstract

Determining Fair Use and the Role of Transformative Use Test
- On the Rulings in Wofsy v. De Fontbrune -

Park, Junu*

Recently, as the size of the cultural industry has grown and cultural and informational products that utilize copyrighted materials have increased, there have been notable fair use rulings by the U.S. Supreme Court (such as Google v. Oracle and Andy Warhol v. Goldsmith). Korea Supreme Court upheld an appellate court ruling that the use of nude photographs in satire posters was not fair use. Courts need to show both ① consistency in the application of fair use doctrine in past and recent rulings on new types of cases, and ② that all rulings are consistent with the purpose of copyright law. However, the diversity of types of copyrighted works and uses, and the nature of fair use as a general provision, make this difficult.

In 2022, the Ninth Circuit ruled in the 'Zervos Catalog Case' that the use of copyrighted photographs was not fair use, and the Supreme Court denied certiorari. In this case, both plaintiff and defendant published catalogs of Pablo Picasso's works, and the defendant had used some of the plaintiff's copyrighted photographs. There were virtually no major issues, considering that the catalogs of the plaintiff and defendant were in direct competition and that the defendant had dead-copied the plaintiff's work (photographs). However, the trial court's decision, the appellate court's decision, and the grounds in the petition for certiorari all show common

* Sogang University Lsw School. Professor

problems in determining fair use. Therefore, this case is very useful to exemplify errors and issues in fair use applications.

This article first introduces the 'Zervos Catalog Case' (II), compares and analyzes the rulings and grounds for certiorari petition (III), and examines the relationship between the first factor of fair use and other factors. Then, it argues ① that fair use is a tool for balancing the freedom of expression of both creator and the user (secondary creator or information producer), and for allocating the costs of creation between them, along with creativity (idea-expression dichotomy) and substantial similarity, ② that the Supreme Court in 'Warhol Case' showed the potential to address issues of balancing freedom of expression and of allocation of creation costs in relation to appropriation art, ③ that the second factor might be deleted from the fair use provision, due to the lack of its independent significance, and ④ that the fair use factors should be considered together, not separately, and a final conclusion should be reached in the light of the purposes of copyright law, which should be explicitly stated in Copyright Act (IV).

Keywords

creativity, substantial similarity, fair use, transformative use, freedom of expression, cost of creation, secondary creativity, Andy Warhol, appropriation art

참고문헌

1. 국내문헌

박성호, 『저작권법』, 박영사(2017).
오승종, 『저작권법』, 박영사(2020).

계승균, “저작권과 표현의 자유”, 『산업재산권』, 제69호, 한국지식재산학회(2021).
_____, “책에 수록된 사진 등을 촬영하여 인터넷에 올린 행위에 관한 판례 연구(BGHZ 1 ZR 104/17)”, 『계간저작권』, 제132호, 한국저작권위원회(2020).
권세진, “저작권 침해의 구성요건으로서 공정이용 법리의 역사적 고찰”, 『산업재산권』, 제46호, 한국지식재산학회(2015).
김도경, “응용프로그램인터페이스(API)에 관한 Oracle v. Google 사건판결의 영향과 전망: 공정이용 인정여부를 중심으로”, 『경영법률』, 제30권 제3호, 한국경영법률학회(2020).
김창화, “Google v. Oracle 판결에서의 공정이용에 관한 연구”, 『산업재산권』, 제68호, 한국지식재산학회(2021).
김혜성, “법원, 카탈로그에 수록된 피카소 작품 사진을 이용한 것은 공정이용에 해당한다”, 『저작권동향』, 제19호, 한국저작권위원회(2019).
류시원, “공정이용 판단의 고려요소로서 ‘변형적 이용’의 한계: 미국 연방법원의 Andy Warhol Foundation v. Goldsmith 사건을 중심으로”, 『계간저작권』, 제140호, 한국저작권위원회(2022).
문건영, “미술저작물등의 부수적 이용에 관한 연구: 대법원 2014. 8. 26. 선고 2012도10786 판결(Be the Reds 사건)을 중심으로”, 『계간저작권』, 제125호, 한국저작권위원회(2019).
박경신, “차용미술의 저작권법상 허용범위의 미적 판단 기준: 절차적 기준 정립을 중심으로”, 『계간저작권』, 제129호, 한국저작권위원회(2020).
손승우/권세진, “노래비 제작을 위한 저작물 이용의 공정이용 분석”, 『스포츠엔터테인먼트와법』, 제25권 제1호, 한국스포츠엔터테인먼트법학회(2022).
신동룡, “18세기 영국에서의 ‘공정하고 선의의 요약 원리’에 대한 연구”, 『계간저작권』, 제109호, 한국저작권위원회(2015).
육소영, “오라클과 구글의 저작권 분쟁과 산업계의 영향”, 『IT와법연구』, 제22집, 경북대학교 IT와법연구소(2021).

이상정, “차용미술(appropriation art)과 저작권”, 『서울법학』, 제18권 제1호, 서울시립대학교 법학연구소(2010).
이일호, “우리 저작권법상 공정이용의 운영 현황과 과제: 판례를 중심으로”, 『계간저작권』, 제141호, 한국저작권위원회(2023).
정진근, “Google v. Oracle 판결에서의 저작물 공정이용(fair use) 법리: 관련 산업에의 영향”, 『산업재산권』, 제68호, 한국지식재산학회(2021).
조채영, “공정이용과 동일성유지권의 충돌에 관한 연구: 현대예술에서 독창성의 의미와 차용예술을 중심으로”, 연세대학교, 박사학위논문(2016).
_____, “미국 저작권법상 공정이용 요건 중 변형성과 잠재적 시장에 미치는 효과의 판단 기준에 대한 판례 검토”, 『과학기술과법』, 제11권 제2호, 충북대학교 법학연구소(2020).
최상필, “패러디의 허용 범위와 표현의 자유: 대법원 2020. 6. 25. 선고 2017도5797 판결을 참고하여”, 『산업재산권』, 제72호, 한국지식재산학회(2022).
최푸름, “제9회순회항소법원, 외국 법원의 저작권 침해 판결 인정과 보상금 산정을 위해 캘리포니아 인정법 적용”, 『저작권동향 2022』, 한국저작권위원회(2022).

전하영, “[아트테크가 뭐길래] 아트테크 입문자가 알아두면 좋을 기본 용어”, 동아일보, 2021. 8. 2.
양경록, “알면 알수록 빠져드는 미술세계 엿보기”, 카이스트신문, 2021. 10. 5.

대법원 2020. 6. 25. 선고 2017도5797 판결(열정페이포스터).
대법원 2017. 11. 9. 선고 2014다49180 판결(짝).
대법원 2014. 8. 26. 선고 2012도10786 판결(Be the Reds).
서울중앙지방법원 2021. 1. 22. 선고 2019나28156,2019나45076 판결(소양강처녀).

2. 국외문헌

Leval, Pierre N., Toward A Fair Use Standard, 103 HARV. L. REV. 1105 (1990).
Patry, William F., Patry on Fair Use (May 2022 Update).
_____, The Fair Use Privilege in Copyright Law (1985).

Stolz, George, “Authenticating Picasso”, ARTnews, January 2, 2013.

_____, "The $20,000 Picasso Catalogue the Art World Was Waiting For", ARTnews, June 3, 2014.

American Geophysical Union v. Texaco, 60 F.3d 913 (2d Cir. 1995).

Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 143 S.Ct. 1258 (2023).

Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd., 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006).

Cambridge Univ. Press v. Patton, 769 F.3d 1232 (11th Cir. 2014).

Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 114 S.Ct. 1164 (1994).

Compaq Computer Corp. v. Ergonome Inc., 387 F.3d 403 (5th Cir. 2004).

De Fontbrune v. Wofsy, 39 F.4th 1214 (9th Cir. 2022), *cert. denied*, 143 S.Ct. 1084 (Apr. 3, 2023).

Disney Enters., Inc. v. VidAngel, Inc., 869 F.3d 848 (9th Cir. 2017).

Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841).

Google LL.C. v. Oracle Am., Inc., 141 S.Ct. 1183 (2021).

Gyles v. Wilcox, 26 Eng. Rep. 489, 2 Atk. 141 (1740).

Harper & Row Publ'ers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539, 105 S.Ct. 2218 (1985).

Katz v. Google Inc., 802 F.3d 1178 (11th Cir. 2015).

Kelly v. Arriba Soft Corp., 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003).

L. Batlin & Son, Inc. v. Snyder, 536 F.2d 486 (2d Cir. 1976).

Leadsinger, Inc. v. BMG Music Pub., 512 F.3d 522 (9th Cir. 2008).

Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods., 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003).

Monge v. Maya Mags., Inc., 688 F.3d 1164 (9th Cir. 2012).

New Era Publ'ns Int'l, ApS v. Carol Publ'g. Grp., 904 F.2d 152 (2d Cir. 1990).

Nunez v. Caribbean Int'l News Corp., 235 F.3d 18 (1st Cir. 2000).

Sony Computer Entertainment America, Inc. v. Bleem, LLC, 214 F.3d 1022 (9th Cir. 2000).

Ty, Inc. v. Publications Int'l Ltd., 292 F.3d 512 (7th Cir. 2002).

Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. of America, 659 F.2d 963 (9th Cir. 1981), rev'd on other grounds, 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774,

78 L. Ed. 2d 574 (1984).
Wright v. Warner Books, Inc., 953 F.2d 731 (2d Cir. 1991).
Zomba Enters., Inc. v. Panorama Recs., Inc., 491 F.3d 574 (6th Cir. 2007).

H. R. REP. No. 83, 90th Cong., 1st Sess (1967).
Petition for Writ of Certiorari, Wofsy v. De Fontbrune (Filed on 2022. 12. 5)(22-531).